

제8절 상속재산의 분할

제1관 상속재산의 분할에 관한 처분

[가사소송법 제2조 제1항 2.나.10), 마류 가사비송사건]

1. 상속재산분할의 의의 및 성질

피상속인의 사망으로 상속 자격이 있는 사람이 여러 명인 경우에 상속재산은 공유로 한다. 이러한 공동상속인 사이의 공동소유관계를 종료시켜 각자의 상속분을 단독소유자로 하는 것을 상속재산분할이라고 한다. 상속재산분할은 상속개시로 인하여 생긴 공동상속인 사이의 상속재산의 공유관계를 종료시키고, 상속분에 따라 그 배분귀속을 확정하는데 의의가 있다. 상속재산의 분할은 본질이 비송이라는 점에서는 공유물분할과 다를 바 없지만, 집합재산인 상속재산을 가정법원이 후견적 재량에 의하여 공동상속인 간에 배분하는 것이라는 점에서 개개의 물건을 대상으로 하는 공유물분할과 다르다.

2. 상속재산분할의 요건

가. 상속재산에 대하여 공동소유관계가 있을 것

상속인이 1인이면 단독으로 상속되어 재산분할이 이루어지지 않는다.

나. 공동상속인이 확정적으로 정해져 있을 것

상속인이 누구인가는 가족관계등록부를 보면 알 수 있지만 인지되지 않는 혼인 외의 출생자가 있거나, 행방불명의 상속인이 있는 경우가 있다. 이러한 경우 상속인을 확정할 필요가 있다.

다. 분할의 금지가 없을 것

피상속인은 유언으로 상속개시의 날로부터 5년을 초과하지 않는 기간 내의 상속재산의 분할을 금지할 수 있다. 따라서 이러한 피상속인의 유언이 없어야 한다. 일부금지의 경우에는 금지되지 않는 다른 부분에 대해서는 분할하여도 된다. 여기서 일부가 상속재산을 이루는 특정재산을 가리키는가에 대하여 긍정설²⁹⁶⁾과 부정설²⁹⁷⁾이 대립한다. 생각건대 상속

재산 총액의 일정비율에 의한 일부금지라고 새기는 후자가 더 타당하다고 본다.

3. 상속재산분할의 대상

가. 서 설

분할의 대상이 되는 것은 공동상속인이 피상속인으로부터 포괄적으로 승계한 일체의 권리의무이다. 따라서 적극재산뿐만 아니라 소극재산도 포함되고, 임차인으로서의 지위나 매도인으로서의 지위 등과 같은 계약상 또는 법률상의 지위도 포함된다.

상속개시 당시에는 상속재산을 구성하던 재산이 그 후 처분되거나 멸실·훼손되는 등으로 상속재산분할 당시 상속재산을 구성하지 아니하게 되었다면 그 재산은 상속재산분할의 대상이 될 수 없다. 다만 상속인이 그 대가로 처분대금, 보험금, 보상금 등 대상재산(대상재산)을 취득하게 된 경우, 대상재산(대상재산)은 종래의 상속재산이 동일성을 유지하면서 형태가 변경된 것에 불과할 뿐만 아니라 상속재산분할의 본질이 상속재산이 가지는 경제적 가치를 포괄적·종합적으로 파악하여 공동상속인에게 공평하고 합리적으로 배분하는 데에 있는 점에 비추어, 그 대상재산(대상재산)이 상속재산분할의 대상이 될 수 있다(대법원 2022. 6. 30.자 2017스98, 99, 100, 101 결정).

분할대상인지의 여부가 문제되는 것을 살펴보면 다음과 같다.

나. 채 권

채권은 일신전속적인 것을 제외하고 상속된다. 예컨대 외상채권, 예금채권 같은 것은 상속된다. 채권에는 비교적 일신전속적인 것으로서 상속되지 않는 것이 많다. 예컨대 당사자 사이의 개개인의 신뢰관계를 바탕으로 하는 법률관계로서 대리관계, 신원보증인으로서의 지위, 고용계약에서의 권리의무, 부양청구의 당사자로서의 지위 등이 그것이다.

(1) 생명보험청구권

(가) 피상속인이 자기를 피보험자로 하고 보험수익자로서 상속인으로 될 자 중의 자녀나 배우자 중의 어느 한 사람을 지정한 경우

상속인인 수익자는 생명보험금을 보험계약에 의하여 원시적으로 취득한 것이지 상속에 의한 승계는 아니다.²⁹⁸⁾ 이때 상속인이 한정승인이나 상속을 포기해도 보험금을 청구할

296) 박윤직, 앞의 책(상속법), 137면; 지원림, 앞의 책, 2041면.

297) 김주수·김상용, 앞의 책, 600면.

수 있고 그러한 보험금은 상속재산에 포함하지 않는다.

(나) 보험계약자가 자기를 피보험자로 하고 제3자를 보험수익자로 지정한 계약에서
그 수익자가 보험사고의 발생 전에 사망한 경우

상법 제733조 제3항에 “보험수익자가 보험존속 중에 사망한 때에는 보험계약자는 다시 보험수익자를 지정할 수 있다. 이 경우에 보험계약자가 지정권을 행사하지 아니하고 사망한 때에는 보험수익자의 상속인을 보험수익자로 한다.”라고 규정하고 있다. 따라서 이 경우 보험금청구권도 상속재산이 되지 않는다.²⁹⁹⁾ 상속인의 고유재산이다.

(다) 보험계약자가 자기를 피보험자로 하는 동시에 보험수익자로 한 경우

피보험자이며 보험수익자인 계약자가 사망하면 그 자의 상속인이 보험수익자의 지위를 상속하고 보험금청구권은 상속재산에 속한다는 것이 일반적이다(다수설). 이에 대하여 상법 제733조 제4항에 유추하여 상속인이 수익자로 지정하고 있는 것으로 추정하여 상속인이 그 고유의 권리로서 원시적으로 생명보험청구권을 취득한다는 것이 판례³⁰⁰⁾의 태도이다.

(라) 피보험자의 상속인을 보험수익자로 하여 맺은 생명보험계약에서 피보험자가 사망하여 보험사고가 발생한 경우

이 경우 상속인이 가지는 보험금청구권이 상속재산인지 여부에 대하여 판례³⁰¹⁾는 “생명보험의 보험계약자가 스스로를 피보험자로 하면서, 수익자는 만기까지 자신이 생존할 경우에는 자기 자신을, 자신이 사망한 경우에는 ‘상속인’이라고만 지정하고 그 피보험자가 사망하여 보험사고가 발생한 경우, 보험금청구권은 상속인들의 고유재산으로 보아야 할 것이고, 이를 상속재산이라 할 수 없다.”고 하였다.

(2) 유족급여

상속재산분할의 대상으로 되지 않는다. 공무원연금법, 사립학교교직원연금법, 기타 사회보장에 관한 법률에서 지급하는 유족연금은 당해 법률에서 수급권자의 순위나 지급방법을 별도로 규정하고 있음으로 유족급여는 수급권자의 고유권리일 뿐 상속재산에 해당하지

298) 대법원 2001. 12. 24. 선고 2001다65755 판결.

299) 대법원 2001. 12. 28. 선고 2000다31502 판결.

300) 대법원 2004. 07. 09. 선고 2003다29463 판결; 대법원 2002. 02. 08. 선고 2000다64502 판결.

301) 대법원 2001. 12. 28. 선고 2000다31502 판결.

않는다. 상조회에서 지급하는 사망위로금 등은 법률에 의한 유족급여와는 성질을 달리하지만, 상조회의 내부규정상 그 지급대상이나 지급방법의 정함이 있으면 그에 의하고 그렇지 않는 경우에는 유족인 배우자 및 자녀들에게 균분으로 지급되는 것으로 보아야 하며, 따라서 상속재산분할의 대상으로 되지 않는다는 실무례가 있다.³⁰²⁾

(3) 손해배상청구권

(가) 통상의 재산권에 대한 손해배상청구권

당연히 상속된다(민법 제1005조).

(나) 약혼해제, 혼인무효취소, 이혼무효취소, 입양무효취소, 파양 등을 이유로 하는 위자료청구권

계약이 성립되거나 소를 제기한 후에만 상속된다. 판례³⁰³⁾도 같은 입장이다.

(다) 생명침해로 인한 정신적 손해배상청구권

① 재산상손해배상청구 : 상속설과 일정한 범위의 사람에게 원시적으로 취득할 것인가(고유피해설) 문제가 있으나, 판례³⁰⁴⁾는 상속설을 채용하고 있다.

② 위자료청구권 : 당연상속설,³⁰⁵⁾ 상속부정설³⁰⁶⁾이 대립하나, 판례³⁰⁷⁾는 상속긍정설에 따른다.

(라) 분배농지에 관한 손해배상청구권

공무원들의 불법행위로 말미암아 분배농지에 관한 권리를 상실한 피상속인이 사망한 이후 상속인들이 위 분배농지에 관한 손해배상청구권에 관하여 상속재산분할협의를 하였는데, 위 채권이 상속재산분할의 대상이 될 수 있는지 문제 된 사안에서, 피상속인의 사망 당시에는 분배농지에 관한 권리가 상속재산분할의 대상이 되는 상속재산이었다가 구 농지법(2007. 4. 11. 법률 제8352호로 전부 개정되기 전의 것) 부칙(1994. 12. 22.) 제3조에서 정한 3년의 기간이 지나 소멸하였고, 이에 따라 상속재산분할협의 당시에는 수분배권의 대상재산(대상재산)인 손해배상청구권이 상속재산분할의 대상이 된다.³⁰⁸⁾

302) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅱ)], 612면.

303) 대법원 1993. 05. 27. 선고 92므143 판결.

304) 대법원 1966. 02. 28. 선고 65다2523 판결.

305) 곽윤직, 『채권각론』, 박영사, 1995, 758면.

306) 이은영, 『채권각론』, 박영사, 1993, 760면.

307) 대법원 1973. 09. 25. 선고 73다1100 판결; 대법원 1969. 04. 15. 선고 69다268 판결.

(4) 부양청구권, 재산분할청구권, 상속회복청구권

(가) 부양청구권

원칙적으로 상속성이 부정되지만 부양에 관한 협의·조정·심판 등에 의하여 부양의 범위가 구체적으로 확정되어 있고 이행기가 도달되어 있으면 상속이 되므로 분할대상이 된다.

(나) 재산분할청구권

이혼에 따른 재산분할청구권도 협의·조정·심판 등에 의하여 구체적인 재산상의 의무이행을 구할 수 있는 경우에도 상속되므로 분할대상이 된다. 그러나 부양적 요소는 상속되지 않는다.³⁰⁹⁾

판례³¹⁰⁾는 “사실혼관계의 당사자 중 일방이 의식불명이 된 상태에서 상대방이 사실혼관계의 해소를 주장하면서 재산분할 심판청구를 한 사안에서, 위 사실혼관계는 상대방의 의사에 의하여 해소되었고 그에 따라 재산분할청구권이 인정된다.”고 보았다.

(다) 상속회복청구권

상속성에 대하여 적극설과 소극설이 대립하고 있다.

(5) 금전채무

채무는 부부의 한쪽이 혼인 중 제3자에게 부담하는 일상가사에 관한 것으로 부부쌍방이 연대책임을 져야 하는 경우를 제외하고는 원칙적으로 개인채무로서 청산의 대상이 되지 않는다. 그러나 공동재산의 형성에 수반하여 부담한 채무인 경우에는 분할대상이 될 수 있다.³¹¹⁾ 그리고 금전채무와 같이 급부의 내용이 가분인 채무가 공동상속된 경우, 이는 상속개시와 동시에 당연히 법정상속분에 따라 공동상속인에게 분할되어 귀속되는 것이므로 상속재산분할의 대상이 될 여지가 없다.³¹²⁾

금전채권과 같이 급부의 내용이 가분인 채권은 공동상속되는 경우 상속개시와 동시에 당연히 법정상속분에 따라 공동상속인들에게 분할되어 귀속되므로 상속재산분할의 대상

308) 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018다238865 판결.

309) 박윤직, 앞의 책(상속법), 76면; 김주수·김상용, 앞의 책, 549면; 이경희, 앞의 책, 376면.

310) 대법원 2009. 02. 09.자 2008스105 결정.

311) 대법원 1993. 05. 25. 선고 92므501 판결.

312) 대법원 1997. 06. 24. 선고 97다8809 판결.

이 될 수 없는 것이 원칙이다. 그러나 가분채권을 일률적으로 상속재산분할의 대상에서 제외하면 부당한 결과가 발생할 수 있다. 예를 들어 공동상속인들 중에 초과특별수익자가 있는 경우 초과특별수익자는 초과분을 반환하지 아니하면서도 가분채권은 법정상속분대로 상속받게 되는 부당한 결과가 나타난다. 그 외에도 특별수익이 존재하거나 기여분이 인정되어 구체적인 상속분이 법정상속분과 달라질 수 있는 상황에서 상속재산으로 가분채권만이 있는 경우에는 모든 상속재산이 법정상속분에 따라 승계되므로 수증재산과 기여분을 참작한 구체적 상속분에 따라 상속을 받도록 함으로써 공동상속인들 사이의 공평을 도모하려는 민법 제1008조, 제1008조의2의 취지에 어긋나게 된다. 따라서 이와 같은 특별한 사정이 있는 때는 상속재산분할을 통하여 공동상속인들 사이에 형평을 기할 필요가 있으므로 가분채권도 예외적으로 상속재산분할의 대상이 될 수 있다.³¹³⁾

(6) 보증채무

보증채무는 상속되는 것이 원칙이다. 그러나 주채무자와 보증인 사이의 신뢰관계에 기초하고 주채무에 수반하여 그 성질이 지배되므로 개별적으로 검토하여야 한다.

(가) 통상적인 보증채무

상속성이 인정된다.

(나) 신원보증채무

신원보증인의 사망은 신원보증채무의 효력을 상실하게 하는 사유(신원보증법 제7조)이므로 상속성이 부정된다. 다만, 신원보증인이 사망하기 전에 신원보증계약을 기초로 이미 보증채무가 발생한 때에는 상속인에게 그 채무는 상속된다.³¹⁴⁾

(다) 계속적 보증채무

계속적 거래관계(예컨대 당좌대월계약, 어음할인계약, 임대차계약, 고용계약 등)에서 생기는 불확정한 채무에 관하여 행해지는 계속적 보증에 있어서는 책임한도액과 보증기간을 정하지 않는 것이 보통이다. 민법은 이에 관하여 아무런 규정을 두고 있지 않다. 따라서 책임에 한도가 있는 경우에만 상속성이 인정된다고 보는 것이 타당하다. 판례³¹⁵⁾도 원칙적으로 상속되지 않는다고 할 것이나, 책임에 한도가 있는 경우에는 상속성이 인정된다는 태도이다.

313) 대법원 2016. 5. 4. 자 2014스122 결정.

314) 대법원 1967. 04. 18. 선고 66다2240 판결; 대법원 1972. 2. 29. 선고 71다2747 판결.

315) 대법원 2003. 12. 26. 선고 2003다30784 판결.

(7) 주택임대차보증금채무

(가) 임대차보증금반환채무의 성격

다수설과 판례는 불가분채무에 속한다고 한다. “건물의 공유자가 공동으로 건물을 임대하고 보증금을 수령한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 임대는 각자 공유지분을 임대한 것이 아니고 임대목적물을 다수의 당사자로서 공동으로 임대한 것이고, 그 보증금반환채무는 성질상 불가분채무에 해당된다고 보아야 한다.”는 것이 판례³¹⁶⁾이다.

(나) 심판에 의한 분할 대상이 되는지 여부

① 분할 대상이 되지 않는다고 하는 하급심판례 : 상속채무는 권리와는 별도로 법정상속분의 비율에 따라 공동상속인이 당연히 상속하게 되는 것이어서 재판에 의하여 상속재산을 분할함에 있어서는 채무는 그 분할의 대상이 되지 않는다.³¹⁷⁾

피상속인의 예금채권 등의 가분채권 또는 채무는 상속개시와 동시에 공동상속인들에게 그 법정상속지분에 따라 법률상 당연히 분할되어 귀속 또는 승계되므로, 위와 같은 채권은 분할의 대상이 되는 상속재산에 포함되지 아니하고, 또 상속재산분할에 있어 채무는 고려될 성질의 것이 아니어서 상속재산가액에서 이를 공제하고 순재산액만을 분할의 대상으로 삼아야 하는 것은 아니다.³¹⁸⁾

② 분할대상이 된다고 하는 하급심판례 : 피상속인의 임대차보증금 반환채무는 불가분의 채무로서 상속재산 분할 대상에 포함되나, 피상속인의 차용금 채무는 상속개시와 동시에 상속인들에게 그 법정상속분에 따라 법률상 당연히 분할되어 승계되는 것으로서 상속재산 분할 대상에 포함되지 아니하고, 상속인이 상속개시 후 상속재산을 임대함으로써 발생한 임대차보증금 반환채무는 그 상속인 개인의 채무에 불과하여 상속재산 분할 대상에 포함되지 아니한다. 이 사건 상속재산의 분할방법은 피상속인의 배우자인 상속인이 상속재산인 부동산을 임대하는 등 직접 관리하고 있고 그 부동산에 대하여 기여분을 인정받았을 뿐만 아니라 다른 상속인들의 일부와 이해관계가 대립하는 등의 사정을 고려하여, 상속재산인 부동산을 배우자인 상속인에게 귀속시키고 나머지 상속인들에게 상속분에 해당하는 금원을 분할하게 함이 적당하다.³¹⁹⁾

316) 대법원 1998. 12. 08. 선고 98다43137 판결.

317) 서울가정법원 1996. 07. 24. 선고 95드74936, 74943, 96느273 판결: 항소.

318) 서울고등법원 1991. 01. 18. 선고 89르2400 판결: 상고기각.

319) 서울가정법원 1995. 09. 07. 선고 94느2926 심판: 항고.

(8) 주식 및 투자신탁의 수익권이 상속재산분할의 대상이 되는지 여부

“상속재산의 분할은 상속에 의하여 공동상속인에게 귀속한 권리를 기초로 하여 구체적인 개개의 상속재산을 각 공동상속인에게 확정적으로 이전시키는 절차로서 각 공동상속인에게 이미 귀속되어 있는 권리, 의무의 교환, 양도, 포기 등이 행하여지는 것이므로 주식(비상장회사의 기명주식)과 같은 재산도 당연히 분할의 대상이 되는 상속재산에 포함된다.”는 하급심판례³²⁰⁾가 있다.

상속재산 중 비상장주식의 가액 산정 방법으로는 한국증권거래소에 상장되거나 한국증권업협회에 등록되지 않은 법인이 발행한 주식의 경우 그에 관한 객관적 교환가치가 적정하게 반영된 정상적인 거래의 실례가 있다면 그 거래가격을 시가로 보아 주식의 가액을 평가하여야 할 것이나, 주식의 객관적 교환가치가 적정하게 반영된 정상적인 거래의 실례가 없는 경우에는 당해 법원이 적정하다고 인정하는 평가방법에 의하여 비상장주식의 가액을 평가할 수 있다.³²¹⁾

투자신탁의 수익권은 금전적인 권리뿐만 아니라 단체법적 권리가 불가분으로 결합한 권리로서, 예금채권 등 단순한 금전채권과는 구별된다. 자본시장법 제189조 제1, 2항에 따르면 집합투자업자는 투자신탁의 수익권을 균등하게 분할하여 수익증권을 발행하고, 수익자는 신탁원본의 상환 및 이익의 분배 등에 관해 수익증권의 좌수에 따라 균등한 권리를 가지게 되는데, 투자신탁의 수익권이 상속 개시와 동시에 당연히 상속인들에게 법정상속분에 따라 분할되어 귀속된다고 볼 경우, 1구좌 미만으로 분할이 불가능한 투자신탁의 수익증권이 1구좌 미만으로 분할되는 문제점이 발생할 수 있다. 피상속인의 주주의 지위, 즉 주식의 경우에도 의결권 등 단체법적 권리로서의 특성과 단주 발생으로 인한 문제점 등을 고려할 때 가분채권으로서 상속 개시와 동시에 공동상속인에게 분할되어 귀속된다고 보기 어렵고, 이에 따라 공동상속인의 준공유로 되어 상속재산분할의 대상이 된다고 할 것인데,³²²⁾ 위와 같은 특성에 비추어 투자신탁의 수익권은 단순한 예금채권 등 금전채권보다는 주식과 유사하게 취급하는 것이 타당하다고 판단된다.³²³⁾

(9) 예금채권

공동상속인 중 초과특별수익자가 존재하는 경우 예금채권과 같은 가분채권이 상속재산

320) 서울고등법원 1992. 03. 31. 선고 88르3635 판결.

321) 서울가정법원 2004. 09. 16. 선고 2000느합61 판결: 항고.

322) 대법원 2003. 5. 30. 선고 2003다7074 판결 등.

323) 서울중앙지방법원 2017. 5. 11. 선고 2016가합545847 판결.

분할 대상에 속하는지? 하급심³²⁴⁾은 “예금채권과 같은 가분채권은 상속개시와 동시에 공동상속인들에게 그 법정상속분에 따라 분할되는 것이 원칙이기는 하나, 상속인 중 초과특별수익자가 있는 경우 가분채권을 상속재산분할 대상에서 제외하면 초과특별수익자는 초과수익을 반환하지 않으면서도 가분채권에 대하여는 법정상속분의 비율로 분할 받게 되고, 또 상속재산으로 가분채권만 있는 경우 특별수익자는 자기의 상속분 이상으로 분할 받게 되고 기여자는 기여분을 평가받지 못하게 되어 공동상속인 간에 불공평한 결과가 생기게 되므로, 특별수익이나 기여분으로 인하여 법정상속분의 재조정이 이루어져야 하는 경우에는 공동상속인들 사이의 형평을 기하기 위하여 가분채권을 분할대상인 상속재산에 포함시키는 것이 타당하다.”고 하였다.

상속재산 중 채권이 가분채권인 금전채권(예컨대 예금채권이나 손해배상채권 등)의 경우, 공동상속인 1인이 법정상속지분에 따라 귀속된 채권액을 한도로 채무자에게 단독으로 청구할 수 있는가, 또는 공동상속인 각자가 채권전액을 청구할 수 있는가, 아니면 공동상속인 전원이 공동으로 상속예금 전액을 청구해야 하는가 문제이다.³²⁵⁾ 불가분채권·채무는 성질상 공유설을 취하든 합유설을 취하든 공동상속의 경우에도 불가분채권·채무의 법리(민법 제409조 내지 제411조)가 적용된다. 반면 가분채권·채무의 경우 당연히 분할되어 상속재산심판대상이 되지 않는가 문제이다. 학설은 공유설³²⁶⁾과 합유설³²⁷⁾로 나뉜다.

가분채권의 경우 판례는 ① “손해배상청구권을 상속한 공동상속인들의 청구를 인정함에 있어서 각자의 상속분이 법정되어 있음에도 불구하고 배상의무자에 대하여 전액에 대한 연대지급을 명한 것은 위법하고,”³²⁸⁾ 또 ② “불법행위로 사망한 피해자들의 상속인들이

324) 서울가정법원 2005. 05. 19. 선고 2004누합152 판결: 항고.

325) 상세한 사항은 김현선, “예금주가 사망한 경우 상속예금에 대한 법률관계(공동상속인 1인이 자기 법정상속지분만큼 단독청구 할 수 있는지 여부)”, 금융법연구(제9권 제2호), 한국금융법학회, 2012. 12. 참조.

326) 공유설은 가분채권은 상속개시와 동시에 공동상속인 사이에 그들의 법정상속분의 비율에 따라 당연히 분할되어 승계된다는 견해로 상속재산분할의 대상이 되지 않는다는 당연분할설(곽윤직, 앞의 책, 232면)과 불가분채권설(김주수·김상용, 앞의 책, 572면)로 나뉜다.

327) 상속한 채권이 가분채권이라 할지라도 상속재산에 귀속한다. 상속재산에 귀속하여 합유재산을 구성한다고 하지만 상속재산은 독립한 재단이 아니므로 형식적으로는 불가분채권의 경우와 같이 공동상속인 전원에게 귀속하며 상속개시와 동시에 당연히 분할되지 않는 것이다. 이 견해는 채권도 상속재산분할심판대상이 된다. 상속재산을 분할한 후에는 분할채권으로 된다(박병호, 앞의 책, 350면).

328) 대법원 1962. 5. 3. 선고 4294민상1105 판결; 이 판결은 상속재산인 채권은 분할하여 상속되는 것이며, 그 점을 기초로 하여 반환하여야 할 의무가 생기는 경우에도 분할채무일 뿐

그 상속분에 따라 각자 손해배상청구를 하고 이에 의한 가집행선고부 제1심판결에 기하여 각기 강제집행을 하였다면 제1심판결의 변경으로 인한 가집행물의 반환채무는 연대채무가 아니라 각자가 별도로 부담하고 있는 채무이고,³²⁹⁾ 그리고 ③ “금전채권과 같이 급부의 내용이 가분인 채권이 공동상속된 경우 이는 상속개시와 동시에 당연히 법정상속분에 따라 공동상속인에게 분할되어 귀속된다.”³³⁰⁾라고 하였지만, 위 판례의 취지만으로 명확히 당연 분할설이라고 할 수 없다고 한다. 그런데 예금채권과 관련하여 최근 대법원판례³³¹⁾는 예외적인 경우 상속재분할대상이 된다고 판시하고 있다. 즉, “예금채권과 같은 가분채권은 상속개시와 동시에 공동상속인에게 그 법정상속분에 따라 분할되는 것이 원칙이기는 하나, 상속인 중 초과수익특별자가 있는 경우 가분채권을 상속재산분할 대상에서 제외하면 초과특별수익자는 초과수익을 반환하지 않으면서도 가분채권에 대하여는 법정상속분의 비율로 분할받게 되고, 또 상속재산으로 가분채권만 있는 경우 특별수익자는 자기의 상속분 이상으로 분할받게 되고 기여자는 기여분을 평가받지 못하게 되어 공동상속인 간에 불공평한 결과가 생기게 되므로, 특별수익이나 기여분으로 인하여 법정상속분의 재조정이 이루어져야 하는 경우에는 공동상속인들 사이의 평형을 기하기 위하여 가분채권을 분할대상인 재산상속에 포함시키는 것이 타당하다 할 것인바, 이 사건의 경우 예금채권 등 가분채권이 상속재산의 적지 않은 부분을 차지하고 있고, 초과특별수익자가 존재하므로, 공동상속인들

연대채무가 되는 것이 아니라는 취지에 불과하고 결코 상속재산인 채무가 분할대상이 된다거나 그렇지 않다는 점에 대한 판례가 아니라고 한다(임채웅, 『상속법연구』, 박영사, 2011, 86면).

329) 대법원 1980. 11. 25. 선고 80다1847 판결; 이 판결은 채권이 아니라 채무상속에 관한 것이다. 채무는 채권에 대응하는 것이기는 하지만, 상속재산분할절차를 통한 분할가능성의 면에서는 동일시하기 어려운 면이 있다. 즉, 채권의 분할은 그 분할로서 채무자의 이해관계에 영향을 주지 않고 따라서 채권자들 사이의 분할만으로도 효력이 있지만, 채무는 그렇지 않다. 채무의 분할로 인하여 법정상속분에 따른 상속과 다른 형태의 상속이 이루어지면 이는 채무의 면책적인수가 시도되는 것이 되어, 채권자가 승인하지 않는 한 아무런 효력이 없다. 따라서 이 점을 적시한 판결의 판시는 너무나 당연한 것이다. 그러나 그 판시가 곧바로 채권에 대해서도 그대로 적용된다고 하는 것은 속단이라고 한다(임채웅, 앞의 책, 86-87면).

330) 대법원 2006. 6. 30. 선고 2005도5338 판결; 이 판결은 채권과 채무의 차이를 무시하고 대법원 1997. 6. 24. 선고 97다8809 판결을 인용하였는데, 어쨌든 상속으로 인하여 채권이 당연히 분할되어 상속인들에게 귀속됨을 규정하고 있을 뿐, 그로 인하여 상속재산분할절차의 심리대상이 될 수 없다고 단정하고 있는 것은 아니라고 한다(임채웅, 앞의 책, 87면).

331) 대법원 2007. 03. 09. 자 2006스88 결정.

간의 평형을 기하기 위하여 위 각 채권을 분할 대상인 상속재산에 포함시킴이 상당하다”고 실시하였다. 이처럼 판례는 원칙적으로 당연분할설을 취하면서 예외적으로 특별한 사정이 있는 경우 상속재산분할절차의 심리대상이 될 수 있다고 판시하였다.

한편, 하급심은 “분할의 대상은 아니지만 공동상속인들이 분할의 대상으로 삼고자 할 때는 분할이 될 수 있다.”³³²⁾하고, “피상속인의 예금채권 등의 가분채권 또는 채무는 상속 개시와 동시에 공동상속인들에게 그 법정상속지분에 따라 법률상 당연히 분할되어 귀속 또는 승계되므로, 위와 같은 채권은 분할대상이 되는 상속재산에 포함되지 아니한다.”³³³⁾고 하였는데, 최근 하급심판례도 당연분할설을 취하고 있다.

가분채무의 경우 판례³³⁴⁾는 금전채무와 같이 급부의 내용이 가분인 채무가 공동상속된 경우, 이는 상속 개시와 동시에 당연히 법정상속분에 따라 공동상속인에게 분할되어 귀속 되는 것이므로, 상속재산분할의 대상이 될 여지가 없다는 당연분할설을 취한다. 또한 “상속인이 2인 이상인 경우에 그중의 한 사람이 피상속인의 재산을 실질적으로 단독상속하였다 하더라도 그 상속인에게 승계되는 피상속인의 국세 등에 관한 납부의무는 민법의 규정에 의한 자기의 상속분에 따라 안분 계산한 금액 범위에 한정되는 것이다”라고 판시하여 상속인들이 원래 상속분대로 국세 등에 관한 납부의무가 상속된다고 하였다.³³⁵⁾

우리 민법과 같은 규정을 취한 일본 판례도 가분채권³³⁶⁾·채무³³⁷⁾의 공동상속은 당연 분할설을 취하고 있지만, 최근 예외적으로 특별한 사정이 있는 경우 당연히 분할되지 않고 상속재산분할의 대상된다는 판례³³⁸⁾가 있다. 현재 재판실무처리는 거의 예외 없이 채권도 모두 상속재분할대상으로 삼고 있다고 한다. 채권도 분할대상으로 삼아 청구함에 대하여 대항하는 쪽에서 상기 판례들을 거론하여 분할대상이 될 수 없다고 주장하는 예가 간혹 있기는 하나, 재판실무에서는 전혀 고려되지 않고 있다고 한다.³³⁹⁾ 만일 채권을 분할대상

332) 서울가정법원 1985. 08. 19. 자 83드6029 심판.

333) 서울가정법원 1991. 01. 18. 선고 89르2400 판결.

334) 대법원 1997. 06. 24. 선고 97다8809 판결.

335) 대법원 1983. 06. 14. 선고 83누175 판결.

336) 最判 昭和29. 04. 08. 民集 第8卷4号, 819頁; 最判 昭和30. 05. 31. 民集 第9卷6号 793頁; 最判 平成17. 09. 08. 民集 第59卷7号, 1931頁(상속개시부터 유산분할까지의 사이에 공동상속과 관련되는 부동산으로부터 발생하는 금전채권인 임대료 채권은 각 공동상속인이 그 상속분에 따라 분할 단독 채권으로 해서 확정적으로 취득한다); 京都地方裁判所 平成20. 04. 24. 平成19(ワ)788.

337) 最判 昭和34. 06. 19. 民集 第13卷6号 757頁; 最判 平成8. 11. 26. 民集 第50卷10号, 2747頁; 最判 平成21. 03. 24. 民集 第63卷3号, 427頁.

338) 最判 平成22. 10. 08. 民集 第64卷7号, 1719頁.

339) 임채웅, 앞의 책, 87면.

으로 삼지 않으면 채권은 법정상속분대로 분할됨을 전제로 하고, 그 점까지 고려하여 분할 방법을 정해야 하는데 이는 매우 복잡하면서도 의미 없는 일이기도 하고, 대부분의 상속인들이 바라는 바도 아니라고 한다.³⁴⁰⁾ 또한 판례에서 ‘채권은 가분이므로 당연히 분할상속된다’는 표현에도 미진한 점이 있다고 한다. 예를 들어 부동산도 지분으로 얼마든지 가분이 될 수 있기 때문이다.³⁴¹⁾

생각건대 우리 민법은 다수당사자 사이의 채권관계는 분할채권관계를 원칙으로 하고 있고, 판례도 원칙적으로 가분채권은 상속개시와 동시에 법정상속지분에 따라 법률상 당연히 분할되어 귀속 또는 승계되므로, 상속재산분할협의의 대상이 되지 않는다고 하는 것이 타당하다고 한다. 다만 판례처럼 예외적으로 초과특별수익자가 존재하거나, 공동상속인들이 합의로 분할의 대상으로 삼고자 하는 경우 금전채권의 특성상 분할되면 그 취지에 반하는 경우에는 당연히 분할되지 않는다고 새겨야 할 것이다.

문제는 이 논문의 주제와 같이 공동상속인 중 1인이 자기 상속지분만큼 금융기관에 단독청구를 한 경우 금융기관은 그 요구에 지급하여야 하는가이다. 앞서 당연분할설에 의하면 금융기관은 당연히 지급해야 하는 것이고, 분할채권설과 합유설은 지급을 거절할 수 있고, 우리 판례는 적지 않게 예외적으로 특별한 사정이 있는 경우 지급을 거절할 수 있는 절충설을 취한다고 한다.³⁴²⁾ 우리 판례가 취하는 절충설에 입각하여 이 문제를 해결하려고 해도 문제점은 발생한다. 왜냐하면, 공동상속인들의 합의가 있거나 특별수익자가 청구하는지 여부 등을 제3자인 금융기관이 알기 어렵기 때문이다. 따라서 금전채권을 제외한 가분채권은 예외적인 경우에 한하여 상속재산분할대상이 된다고 하되, 가분채권 중 금전채권은 당연분할설로 처리하는 것이 타당하고 실무상 용이하다. 따라서 채무자인 금융기관은 어느 학설과 판례에 입각하여 예금지급이 곤란하다면, ‘변제공탁’이나 ‘준점유자에 대한 변제’로 처리하면 될 것이다.

340) 임채웅, 앞의 책, 87-88면.

341) 임채웅, 앞의 책, 271면.

342) 법원실무제요에서도 분할의 대상으로 삼기로 하는 공동상속인 사이의 합의가 있거나 가분채권까지 분할하는 것이 구체적 형평에 부합하는 경우에 한하여 분할이 대상이 된다는 절충설을 따르는 예가 적지 않다고 한다[법원행정처, 『법원실무제요(가사, II)』, 2010, 615면].

다. 물 권

(1) 소유권

(가) 원 칙

상속재산에 포함되는 것이 원칙이다. 다만, 농지법 제7조 제3항에 의하면 상속에 의하여 농지를 취득한 자로서 농업경영을 하지 아니하는 자는 그 상속농지 중에서, 대통령령이 정하는 기간 이상 농업경영을 한 후 이농하는 자는 이농당시의 소유농지 중에서 1만 제곱미터 이내의 것에 한하여 이를 소유할 수 있다.

(나) 유 해

장례나 제사를 위하여 소유권을 인정하는 학설과 관리권만을 인정하는 학설이 대립하고 있다. 즉, 유해는 공동상속인의 소유가 아니라 제사를 주재하는 자가 소유한다는 견해와 유해에 대하여는 소유권을 인정할 수 없고 권리만 인정되는 것이 원칙이라는 설이 대립하고 있다.³⁴³⁾ 판례³⁴⁴⁾는 “사람의 유체·유골은 매장·관리·제사·공양의 대상이 될 수 있는 유체물로서, 분묘에 안치되어 있는 선조의 유체·유골은 민법 제1008조의3 소정의 제사용 재산인 분묘와 함께 그 제사주재자에게 승계되고, 피상속인 자신의 유체·유골 역시 위 제사용 재산에 준하여 그 제사주재자에게 승계된다.”고 한다.

임야의 소유권에 터 잡아 분묘의 철거를 청구하려면 분묘의 설치를 누가 하였건 그 분묘의 관리처분권을 가진 자를 상대로 하여야 하고, 종손이 있는 경우라면 그가 제사를 주재하는 자의 지위를 유지할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 일반적으로 선조의 분묘를 수호·관리하는 권리는 그 종손에게 있다고 봄이 상당하므로, 종손이 아닌 자가 제사 주재자로서 분묘에 대한 관리처분권을 가지고 있다고 하기 위하여는 우선 종손에게 제사 주재자의 지위를 유지할 수 없는 특별한 사정이 있음이 인정되어야 한다.³⁴⁵⁾

어느 토지가 민법 제1008조의3 소정의 금양임야이거나 묘토인 농지에 해당한다면 그 규정에 정한 범위 내의 토지는 제사주재자가 단독으로 그 소유권을 승계할 것이고 이때의 제사주재자는 종손이 있는 경우라면 그에게 제사를 주재하는 자의 지위를 유지할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그가 된다 할 것이며, 그 경우 다른 상속인 등의 명의로 소유권이전등기가 경료되었다 하여도 그 부분에 관한 한은 무효의 등기에 불과하므로, 그 소유권이전등기로써 제사주재자가 승계할 금양임야가 일반 상속재산으로 돌아가는

343) 배경숙·최금숙, 앞의 책, 501면.

344) 대법원 2008. 11. 20. 선고 2007다27670 전원합의체 판결.

345) 대법원 1997. 09. 05. 선고 95다51182 판결.

것은 아니다.³⁴⁶⁾

분묘의 부속시설인 비석 등 제구를 설치·관리할 권한은 분묘의 수호·관리권에 포함되어 원칙적으로 제사를 주재하는 자에게 있고, 따라서 만약 제사주재자 아닌 다른 후손들이 비석 등 시설물을 설치하였고 그것이 제사주재자의 의사에 반하는 것이라 하더라도, 제사주재자가 분묘의 수호·관리권에 기하여 철거를 구하는 것은 별론으로 하고, 그 시설물의 규모나 범위가 분묘기지권의 허용범위를 넘지 아니하는 한, 분묘가 위치한 토지의 소유권자가 토지소유권에 기하여 방해배제청구로서 그 철거를 구할 수는 없다.³⁴⁷⁾

(2) 점유권

(가) 점유권의 성질 및 하자

점유권은 승계되며, 점유의 성질 및 하자도 승계된다(민법 제193조). 상속인에게 이전되는 점유권에 관하여는 본법 제1009조 이하에 규정된 상속분에 관한 규정은 적용될 것이 아니다. 수급인이 건축재료의 전부 또는 주요부분을 제공하여 완성한 건물소유권은 원칙적으로 수급인에게 귀속되고 도급인은 수급인으로부터 그 소유권을 이전받음으로써 소유권을 취득한다.³⁴⁸⁾

(나) 포괄승계의 경우 점유승계에 관하여 민법 제199조(점유의 승계의 주장과 그 효과)를 적용하는지 여부

학설은 적용긍정설인 다수설과 적용부정설이 대립하고 있다. 판례는 상속에 의하여 점유권을 취득한 경우에는 상속인은 새로운 권원에 의하여 자기 고유의 점유를 개시하지 않는 한 피상속인의 점유를 떠나 자기만의 점유를 주장할 수 없다.³⁴⁹⁾

(다) 자주점유·타주점유

부동산을 타인에게 매도하여 그 인도의무를 지고 있는 매도인의 점유는 특별한 사정이 없는 한 타주점유로 변경된다. 상속에 의하여 점유권을 취득한 경우에는 상속인이 새로운 권원에 의하여 자기 고유의 점유를 시작하지 않는 한 피상속인의 점유를 떠나 자기만의 점유를 주장할 수 없고, 또 선대의 점유가 타주점유인 경우 선대로부터 상속에 의하여 점유를 승계한 자의 점유도 그 성질 내지 태양을 달리하는 것이 아니어서 특별한 사정이

346) 대법원 1997. 11. 28. 선고 96누18069 판결.

347) 대법원 2000. 09. 26. 선고 99다14006 판결.

348) 대법원 1962. 10. 11. 선고 62다460 판결.

349) 대법원 1972. 06. 27. 선고 72다535, 536 판결; 1992. 09. 22. 선고 92다22602 판결.

없는 한 그 점유가 자주점유로 될 수 없고, 그 점유가 자주점유가 되기 위하여는 점유자가 소유자에 대하여 소유의 의사가 있는 것을 표시하거나 새로운 권원에 의하여 다시 소유의 의사로써 점유를 시작하여야 한다.³⁵⁰⁾

(라) 등기부취득시효와 점유기간

상속인은 상속의 개시 즉 피상속인의 사망이라는 법률요건의 성립에 의하여 피상속인의 재산에 관한 포괄적 권리의무를 승계하고, 권리의 득실변경에 등기를 요건으로 하는 경우에도 상속인은 등기를 하지 아니하고도 상속에 의하여 곧바로 그 권리를 취득하는 것이므로 부동산에 관하여 피상속인 명의로 소유권이전등기가 10년 이상 경료되어 있는 이상 상속인은 부동산등기부 시효취득의 요건인 ‘부동산의 소유자로 등기한 자’에 해당한다고 할 것이어서, 이 경우 피상속인과 상속인의 점유기간을 합산하여 10년을 넘을 때에 등기부 취득시효기간이 완성된다 할 것이다.³⁵¹⁾

(마) 현실적으로 점유하고 있지 않는 공동상속인

그 물건을 점유하는 것으로 볼 것인지에 관하여 견해가 나뉘지만 판례³⁵²⁾는 특별한 사정이 없는 한 현실적인 점유를 하는 자만이 피상속인을 승계하여 그 물건 전체를 점유하는 것으로 보아야 한다고 한다.

(3) 무체재산권

특허권, 상표권, 저작권, 어업권, 의장권, 실용신안권, 및 광업권 등은 상속된다. 그러나 공동광업권자의 지위는 상속되지 않는다. 판례³⁵³⁾는 “공동광업권자의 1인이 사망한 때에는 공동광업권의 조합관계로부터 당연히 탈퇴되고, 특히 조합계약에서 사망한 공동광업권자의 지위를 그 상속인이 승계하기로 약정한 바가 없는 이상 사망한 공동광업권자의 지위는 일신전속적인 권리의무관계로서 상속인에게 승계되지 아니하고, 따라서 동 망인이 제소한 공동광업권관계소송은 그의 사망으로 당연히 종료된다.”라고 판시하고 있다.

라. 사원권 등

합명회사의 사원 및 합자회사의 무한책임사원의 지위는 상속되지 않으나(상법 제218조

350) 대법원 1997. 12. 12. 선고 97다40100 판결.

351) 대법원 1989. 12. 26. 선고 89다카6140 판결.

352) 대법원 1989. 04. 11. 선고 88다카17398 판결.

353) 대법원 1981. 07. 28. 선고 81다145 판결.

제3항, 제269조), 합자회사의 유한책임사원(상법 제283조)과 유한회사의 사원의 지위는 상속되므로 분할대상이 된다. 그리고 합명회사나 합자회사의 지분환급청구권은 상속이 되므로 분할대상이 된다.

마. 제사재산의 승계

(1) 민법 제1008조의3

“분묘에 속한 1정보 이내의 금양임야와 600평 이내의 묘토인 농지, 족보와 제구의 소유권은 제사를 주재하는 자가 이를 승계 한다.”라고 규정하고 있다. 제사의 주재자는 피상속인의 유언이나 생존 중의 말이나 문서로 지정할 수 있고 이러한 지정이 없다면 관습에 따른다. 따라서 이들 재산은 공동상속의 대상이 아니고 따라서 분할의 대상으로 되지 않는다.

(2) 분 묘

사람의 사체, 유골, 유발 등을 매장하여 제사나 예배 또는 기념의 대상으로 하는 장소를 말하는 것이다. 따라서 사체나 유골이 토지화되었을 때에도 분묘인 것이며 그 죽은 자가 누구인지 불명하다고 할지라도 현재 제사를 숭경하고 종교적 예의의 대상으로 되어 있고 이를 수호봉사 하는 자가 있으며 분묘에 해당한다.³⁵⁴⁾

(3) 금양임야

금양임야란 벌목을 금지하고 나무를 기르는 임야를 말하며 종중산을 가리킨다. 수백 년간 선조의 분묘 수집 기가 설치되어 온 사실이 인정되고 후손들이 제사·분묘수호·위토관리를 해온 임야는 비록 타인명의로 등기되어 있다 하더라도 종중산으로 보아야 한다.³⁵⁵⁾

금양임야 등의 소유자가 사망하여 그 상속인과 제사 주재자가 달라진 경우에는 그 금양임야 등이 일반재산으로 돌아가므로 이때는 분할대상이 된다.³⁵⁶⁾

금양임야 등 제사용 재산을 일반상속의 대상에서 제외하여 특별상속에 의하도록 하고 있는 이유는 제사용 재산을 공동상속하게 하거나 평등분할 하도록 하는 것은 조상 숭배나 가통의 계승을 중시하는 우리의 습속이나 국민감정에 반하는 것이므로 일반상속재산과는 구별하여 달리 취급하기 위한 것이라 할 것이므로, 이와 같은 제도의 취지에 비추어 볼 때, 금양임야가 수호하는 분묘의 기지가 제3자에게 이전된 경우에도 그 분묘를 사실상

354) 대법원 1990. 02. 13. 선고 89도2061 판결.

355) 대법원 1987. 07. 14. 선고 85다카1033 판결.

356) 대법원 1994. 10. 14. 선고 94누4059 판결.

이전하기 전까지는 그 임야는 여전히 금양임야로서의 성질을 지니고 있으므로, 금양임야가 수호하던 분묘의 기지가 포함된 토지가 토지수용으로 인하여 소유권이 이전된 후에도 미처 분묘를 이장하지 못하고 있던 중 피상속인이 사망하였다면 위 임야는 여전히 금양임야로서의 성질을 지닌다.³⁵⁷⁾ 피상속인의 사망 당시에 당해 임야에 그 선대의 분묘가 없는 경우에는 그 임야를 금양임야라고 볼 수 없다.³⁵⁸⁾

(4) 묘토(위토)

제사와 이에 관련된 사항을 집행·처리하기 위하여 설정된 토지를 묘토라 한다. 종중과 분묘수호계약에 따라 조성하고 경작관리 하는 논·과수원은 위토의 성격을 갖는다.³⁵⁹⁾ 묘토라 함은 분묘의 수호, 관리나 제사용 자원인 토지로서 특정의 분묘에 속한 것을 말하는 바, 현행 민법이 그 소유권의 귀속주체를 제사를 주재하는 자로 규정하고 있는 점에 비추어 보면, 민법 제1008조의3 소정의 묘토인 농지는 그 경작하여 얻은 수확으로 분묘의 수호, 관리비용이나 제사의 비용을 조달하는 자원인 농토이어야 하고, 그중 제사의 비용을 조달하는 것이 중요한 것이 됨은 분명하나 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.³⁶⁰⁾ 당해 임야나 농지의 현황과 관리상태 등에 비추어 전체적으로 금양임야나 묘토인 농지에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다.³⁶¹⁾ 따라서 지목이 전으로 되어 있으나 도시계획상 일반 주거지에 편입되어 있고 주변 일대가 완전히 도시화되어 있으며, 타인으로 하여금 콩이나 채소 등을 재배하게 하여 그 경작자가 경작대가로 단순히 1년에 한두 번 정도 토지소유자의 조상의 분묘 등 분묘 3기의 벌초를 하여 온 것에 불과하다면, 그 토지를 분묘의 수호, 관리비용을 조달하기 위한 묘토인 농지라고 볼 수는 없다.

(5) 족보와 제구

족보란 일가의 역사와 가계의 연속을 표시하는 책이며, 제구는 조상제사에 사용되는 도구이다.

357) 대법원 1997. 11. 28. 선고 96누18069 판결.

358) 대법원 2001. 02. 27. 선고 2000두703 판결.

359) 대법원 1987. 04. 14. 선고 86다카2342 판결.

360) 대법원 1997. 05. 30. 선고 97누4838 판결.

361) 대법원 2008. 10. 27.자 2006스140 결정 : 피상속인의 사망 당시 그 소유인 토지에 아무런 분묘가 설치되어 있지 아니한 이상 위 토지는 상속재산으로서 상속인들에게 귀속하는 것이고, 피상속인의 사망 후 상속재산인 토지에 피상속인의 분묘를 설치하였다고 하여 그 분묘 기지면적에 해당하는 토지 부분의 소유권이 구 민법 제996조에 의한 제사용 재산으로서 호주상속인에게 단독 승계되는 것은 아니다.

(6) 제사를 주재하는 자

보통 장남이 하지만 장남이 주재할 형편이 되지 못한다거나 지내지 않을 경우에는 가족의 협의에 의하여 제사주재자를 정할 수 있다. 협의가 이루어지지 않는다면 공동승계가 될 수 있다. 판례³⁶²⁾는 “제사주재자의 결정 방법으로 제사주재자는 우선적으로 망인의 공동상속인들 사이의 협의에 의해 정하되, 협의가 이루어지지 않는 경우에는 제사주재자의 지위를 유지할 수 없는 특별한 사정이 있지 않은 한 망인의 장남(장남이 이미 사망한 경우에는 장남의 아들, 즉 장손자)이 제사주재자가 되고, 공동상속인들 중 아들이 없는 경우에는 망인의 장녀가 제사주재자가 된다고 하였고, 어떤 경우에 제사주재자의 지위를 유지할 수 없는 특별한 사정이 있다고 볼 것인지에 관하여는, 제사제도가 관습에 바탕을 둔 것이므로 관습을 고려하되, 여기에서의 관습은 과거의 관습이 아니라 사회의 변화에 따라 새롭게 형성되어 계속되고 있는 현재의 관습을 말하므로 우리 사회를 지배하는 기본적 이념이나 사회질서의 변화와 그에 따라 새롭게 형성되는 관습을 고려해야 할 것인바, 중대한 질병, 심한 낭비와 방탕한 생활, 장기간의 외국 거주, 생계가 곤란할 정도의 심각한 경제적 궁핍, 평소 부모를 학대하거나 심한 모욕 또는 위해를 가하는 행위, 선조의 분묘에 대한 수호·관리를 하지 않거나 제사를 거부하는 행위, 합리적인 이유 없이 부모의 유지 내지 유훈에 현저히 반하는 행위 등으로 인하여 정상적으로 제사를 주재할 의사나 능력이 없다고 인정되는 경우가 이에 해당한다.”고 하였다.

금양임야 등의 소유자가 사망한 후 상속인과 그 금양임야로서 수호하는 분묘의 제사를 주재하는 자가 다를 경우에는 그 금양임야 등은 상속인들의 일반상속재산으로 돌아간다고 보아야 할 것이며 상속인이 아닌 제사를 주재하는 자에게 금양임야 등의 승계권이 귀속된다고 할 수는 없다.³⁶³⁾

임야의 소유권에 터 잡아 분묘의 철거를 청구하려면 분묘의 설치를 누가 하였건 그 분묘의 관리처분권을 가진 자를 상대로 하여야 하고, 종손이 있는 경우라면 그가 제사를 주재하는 자의 지위를 유지할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 일반적으로 선조의 분묘를 수호·관리하는 권리는 그 종손에게 있다고 봄이 상당하므로, 종손이 아닌 자가 제사주재자로서 분묘에 대한 관리처분권을 가지고 있다고 하기 위하여는 우선 종손에게 제사주재자의 지위를 유지할 수 없는 특별한 사정이 있음이 인정되어야 한다.³⁶⁴⁾

362) 대법원 2008. 11. 20. 선고 2007다27670 전원합의체 판결.

363) 대법원 1994. 10. 14. 선고 94누4059 판결.

364) 대법원 1997. 09. 05. 선고 95다51182 판결.

어느 토지가 민법 제1008조의3 소정의 금양임야이거나 묘토인 농지에 해당한다면 그 규정에 정한 범위 내의 토지는 제사주재자가 단독으로 그 소유권을 승계할 것이고 이때의 제사주재자는 종손이 있는 경우라면 그에게 제사를 주재하는 자의 지위를 유지할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그가 된다 할 것이며, 그 경우 다른 상속인 등의 명의로 소유권이전등기가 경료되었다 하여도 그 부분에 관한 한은 무효의 등기에 불과하므로, 그 소유권이전등기로써 제사주재자가 승계할 금양임야가 일반 상속재산으로 돌아가는 것은 아니다.³⁶⁵⁾

분묘의 부속시설인 비석 등 제구를 설치·관리할 권한은 분묘의 수호·관리권에 포함되어 원칙적으로 제사를 주재하는 자에게 있고, 따라서 만약 제사주재자 아닌 다른 후손들이 비석 등 시설물을 설치하였고 그것이 제사주재자의 의사에 반하는 것이라 하더라도, 제사주재자가 분묘의 수호·관리권에 기하여 철거를 구하는 것은 별론으로 하고, 그 시설물의 규모나 범위가 분묘기지권의 허용범위를 넘지 아니하는 한, 분묘가 위치한 토지의 소유권자가 토지소유권에 기하여 방해배제청구로서 그 철거를 구할 수는 없다.³⁶⁶⁾

바. 조의금의 상속재산 여부

조의금은 일반적으로 상속재산으로 취급하지 않는다. 판례도 다음과 같이 취급하고 있다. “사람이 사망한 경우에 부조금 또는 조의금 등의 명목으로 보내는 부의금은 상호부조의 정신에서 유족의 정신적 고통을 위로하고 장례에 따르는 유족의 경제적 부담을 덜어줌과 아울러 유족의 생활안정에 기여함을 목적으로 증여되는 것으로서, 장례비용에 충당하고 남는 것에 관하여는 특별한 사정이 없는 한, 사망한 사람의 공동상속인들이 각자의 상속분에 응하여 권리를 취득하는 것으로 봄이 우리의 윤리감정이나 경험칙에 합치된다고 할 것이다.”³⁶⁷⁾ 따라서 조의금 중 장례비용에 충당하고 남는 것은 공동상속인이 각자 상속분에 따라 권리를 주장할 수 있다.

부의금이란 장례비에 먼저 충당될 것을 조건으로 한 금전의 증여로 이해함이 상당할 것이므로, 접수된 부의금 금액이 상속인 또는 상속인이 아닌 가족(편의상 이들을 ‘부의금 피교부자’라고 한다)별로 다르더라도 동 금원은 모두 장례비로 먼저 충당되어야 하며, 이 점은 부의금 피교부자가 후순위상속인이거나 상속자격이 없는 경우라 하더라도 마찬가지이다. 이러한 점은 생존해 있는 자들과는 별도로 오로지 망인과 관련하여 접수된 부의금도

365) 대법원 1997. 11. 28. 선고 96누18069 판결.

366) 대법원 2000. 09. 26. 선고 99다14006 판결.

367) 대법원 1992. 08. 18. 선고 92다2998 판결; 대법원 1966. 09. 20. 선고 65다2319 판결.

역시 마찬가지인데, 이러한 부의금은 위에서 본 원칙에 따라 장례비용을 부담할 자들에게 그들이 상속받을 경우 적용될 법정상속분의 비율에 따라 증여된 것으로 봄이 상당하다. 그런데 만일 부의금의 총 합계액이 장례비를 상회한다면 부의금 피교부자별로 접수된 금액의 비율대로 각 금액에서 충당하고, 나머지 금액은 각 부의금 피교부자별로 귀속되게 함이 옳다. 이 경우 각 부의금피교부자별 금액이 확정되지 않는다면, 각 부의금 피교부자의 지위에 상관없이 나머지 금액을 평등하게 분배함이 옳다. 한편 부의금의 총 합계액이 장례비에 미치지 못한다면 접수된 부의금은 모두 장례비에 충당되고, 나머지 장례비용은 위에서 본 원칙에 따라 장례비용을 부담하여야 할 자들이, 그들이 상속을 받을 경우 적용되었을 법정상속분에 따라 분담함이 옳다.³⁶⁸⁾

사. 상속재산의 대가로 취득한 재산

상속개시 후에 이루어지는 상속재산의 매각대금, 화재로 멸실된 경우의 화재보험금, 수용에 따른 수용보상금 등에 관하여 상속재산분할의 대상이 되는가? 견해의 대립이 있다. 상속재산분할의 본질은 상속재산이 갖는 경제적 가치를 포괄적, 종합적으로 파악하여 이를 공동상속인에게 그 상속분에 따라 공평하고도 합리적으로 분배하는 것이므로 상속재산과 동일시하여 분할의 대상으로 하는 것이 타당하다는 견해와 일반적으로는 상속재산분할의 대상으로 되지 아니하나 공동상속인 간에 분할의 대상으로 삼기로 하는 협의가 있는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 상속재산분할의 대상으로 할 수 있다는 견해가 있다. 그 밖에 위와 같은 대상재산은 상속재산은 아니고 그 청산은 민사소송법에 의하여야 하는 것으로서 상속재산분할의 대상으로 되지 않는다는 견해가 있다. 하급심판례³⁶⁹⁾에서는 상속부동산의 처분대금을 상속재산분할대상으로 삼고 있다.³⁷⁰⁾ 공유물분할에 관하여 판례³⁷¹⁾는 일반공유물의 대가로 얻은 재산의 민법 제269조에 의한 분할적격성을 부정하고 있다.

아. 상속재산의 법정과실·관리비용

가령 상속부동산의 임료, 예금의 이자, 주식의 배당금 등도 분할의 대상이 되는가. 견해의 대립이 있으나 분할의 대상이 된다는 것이 다수설 입장이다. 즉, 공동상속인간의 평등내

368) 서울가정법원 2010. 11. 02. 자 2008ㄴ합86 심판 : 확정.

369) 서울가정법원 1996. 08. 23. 선고 94ㄴ196 판결.

370) 서울가정법원, “실무연구VI”, 160~161면.

371) 대법원 1970. 04. 14. 선고 70다171 판결.

지 공평을 위해서 상속재산으로부터 발생한 과실 또는 수익도 상속재산분할의 대상으로 삼아야 한다는 견해, 상속재산으로부터 발생하는 과실 또는 수익은 상속재산 그 자체는 아니므로 필요하다면 공유물분할의 절차에 의하여 처리하여야 할 것이지만 공동상속인 전원의 합의가 있는 등 공동상속인 사이의 형평을 도모할 필요가 있는 경우에는 분할의 대상으로 삼을 수 있다는 견해가 있다.³⁷²⁾ 판례³⁷³⁾는 “인지 전에 공동상속인들에 의해 이미 분할되거나 처분된 상속재산은 이를 분할 받은 공동상속인이나 공동상속인들의 처분 행위에 의해 이를 양수한 자에게 그 소유권이 확정적으로 귀속되는 것이며, 그 후 그 상속재산으로부터 발생하는 과실은 상속개시 당시 존재하지 않았던 것이어서 이를 상속재산에 해당한다 할 수 없고, 상속재산의 소유권을 취득한 자(분할 받은 공동상속인 또는 공동상속인들로부터 양수한 자)가 민법 제102조에 따라 그 과실을 수취할 권능도 보유한다고 할 것이며, 민법 제1014조도 ‘이미 분할 내지 처분된 상속재산’ 중 피인지자의 상속분에 상당한 가액의 지급청구권만을 규정하고 있을 뿐 ‘이미 분할 내지 처분된 상속재산으로부터 발생한 과실’에 대해서는 별도의 규정을 두지 않고 있으므로, 결국 민법 제1014조에 의한 상속분상당가액지급청구에 있어 상속재산으로부터 발생한 과실은 그 가액산정 대상에 포함된다고 할 수 없다.”고 한다.

자. 관리비용 · 장례비용

상속개시 후에 상속재산을 유지, 관리하기 위해 지출하는 공조공과, 화재보험료, 부동산에 관한 필요비, 유익비 등은 상속에 관한 비용으로서 상속재산 중에서 지급하는 것인데(민법 제998조의2), 일부 상속인이 위와 같은 비용을 지출한 경우 상속재산분할을 하면서 이를 함께 청산할 수 있는지 문제이다. 실무에서는 상속재산의 유지, 보전을 위해 객관적으로 필요한 비용의 범위 내에서 상속재산에 준하여 청산할 수 있다고 보고 있다. 다만, 상속인의 과실에 의해 지출한 것은 청산의 대상에서 제외되고, 또한 상속재산 결과로 상속재산에 포함되었던 개별적 권리의 이전 등에 필요한 비용은 상속재산의 관리비용이 아니므로 그 권리를 취득하는 상속인이 부담하여야 할 것이다.³⁷⁴⁾ 상속에 관한 비용은 상속재산 중에서 지급하는 것이고, 상속에 관한 비용이라 함은 상속재산의 관리 및 청산에 필요한 비용을 의미하는바, 장례비용도 피상속인이나 상속인의 사회적 지위와 그 지역의 풍속 등에 비추어 합리적인 금액 범위 내라면 이를 상속비용으로 보아야 한다.³⁷⁵⁾ 따라서 위와 같은 범위

372) 서울가정법원, “실무연구VI”, 163~164면.

373) 대법원 2007. 07. 26. 선고 2006므2757, 2764 판결.

374) 법원행정처, 법원실무제요[가사(II)], 616~617면.

내의 장례비용을 일부 상속인이 상주로서 지출하였다면 상속재산분할 시에 이를 함께 청산할 수 있다 할 것이다. 최근 하급심판례³⁷⁶⁾는 장례비 부담원칙을 제시한바, 특별한 사정이 없는 한 장례비용은 민법 제1000조 및 제1003조에 규정된 상속의 순위에 의하여 가장 선순위에 놓인 자들이 각 법정상속분의 비율에 따라 부담함이 원칙이라 할 것이고, 이러한 원칙은 특정 상속인이 상속을 포기하였다고 하더라도 동일하게 적용됨이 마땅하다. 예를 들어, 1순위상속인들이 상속을 포기하였다고 하더라도 그들의 장례비용 부담의무는 면해지지 않는다. 비록 장례비용은 상속비용의 일부로 취급되어 상속재산분할절차에서 고려되나,³⁷⁷⁾ 장례비용의 부담은 상속에서 근거를 두는 것이 아니라, 망인과의 친족관계에서 비롯된 것으로 파악함이 옳을 것이므로, 위 법리는 장례비용을 부담하는 자와 상속인이 일치하는 경우 상속재산분할절차에서 장례비용을 고려할 수 있다는 의미로 이해함이 상당하다.

차. 상속세

상속세는 상속인의 개인적 채무가 아니라 상속으로 발생한 비용이고, 상속재산의 부담이라고 새겨야 할 것이므로, 기타 관리비용과 마찬가지로 상속재산분할 시에 함께 청산할 수 있다고 할 것이다.³⁷⁸⁾

피상속인이 사망한 뒤 친생자로 인지된 상속인 갑에게 이미 상속재산을 협의분할 한 다른 공동상속인 을 등이 반환하여야 할 상속분의 가액에서 을 등이 납부한 상속세 중 갑이 부담하였어야 하는 부분을 공제함에 있어, 을 등을 포함한 다른 공동상속인들이 이미 납부한 증여세액 등을 모두 공제한 뒤 최종적으로 결정된 상속세액을 기준으로 하지 아니하고, 전체 상속세액 중 상속인 이외의 사람에 대한 증여세액 등만을 공제하여 갑을 포함한 공동상속인들이 부담하여야 할 상속세액을 산정한 뒤 이를 기준으로 갑이 부담하였어야 하는 상속세액을 산정하여야 한다.³⁷⁹⁾ 그러나 세금채무에 대하여 분할 대상이 될 수 없다.

상속인은 상속으로 인하여 얻은 자산총액에서 부채총액과 그 상속세를 공제하고 남은 상속재산가액의 한도에서 상속에 인하여 피상속인으로부터 승계한 국세 등 납세의무를 이행할 의무가 있는 것이므로 피상속인으로부터 승계되는 체납국세액은 위 부채총액에

375) 대법원 2003. 11. 14. 선고 2003다30968 판결.

376) 서울가정법원 2010. 11. 02.자 2008느합86, 87 심판: 확정.

377) 대법원 1997. 04. 25. 선고 97다3996 판결.

378) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅱ)], 617면.

379) 대법원 2002. 11. 26. 선고 2002므1398 판결.

포함되지 아니하므로 상속인이 상속 재산의 한도 내에서 승계한 피상속인의 체납국세의 납부의무를 이행하지 아니하는 경우 그 징수를 위해서 하는 압류는 반드시 상속재산에만 한정된다고 할 수 없고 상속인의 고유재산에 대해서도 압류할 수 있다.³⁸⁰⁾

상속개시 후 타인의 대위에 의한 법정상속지분대로의 상속등기가 이루어진 상태를 방치하여 두었다가 10년이 지난 후 위 등기내용과 다른 협의분할에 의한 등기를 하였더라도 증여세 부과대상이 되지 않는다.³⁸¹⁾

파. 배우자로 지정한 퇴직생활급여

갑이 초등학교 교사로써 퇴직 당시 퇴직일시금과 퇴직수당, 교원장기저축금 등을 받아 한국교직원공제회에 퇴직생활급여 상품으로 예치하였는데, 갑의 사망 후 공동상속인인 을 등이 다른 공동상속인인 병 등을 상대로 상속재산분할을 구하면서 갑이 생전에 한국교직원공제회에 예치해 두었던 퇴직생활급여금도 갑이 사망 당시 소유하고 있던 재산으로서 상속재산 분할대상에 해당한다고 주장한 사안에서, 한국교직원공제회가 운영하는 퇴직생활급여 상품은 퇴직 후 가입하는 저축상품으로서 가입자인 갑이 가입기간 동안 부가금(이자)을 지급받고, 급여를 청구할 경우 원리금을 모두 지급받는 구조인데, 가입자가 사망한 경우에 급여 수급권자의 순위는 민법상 재산상속 순위에 따르지만, 가입자가 사망 전에 배우자, 직계비속, 형제자매에 한하여 수급권자를 지정할 수 있으며, 이에 갑이 사망 전에 배우자인 병을 수급권자로 지정하였고, 이에 따라 병이 갑의 사망 후 한국교직원공제회로부터 갑이 생전에 예치한 퇴직생활급여를 받았는데, 이러한 퇴직생활급여의 발생 근거와 성격 등을 종합하면, 퇴직생활급여는 병이 독자적으로 수령할 권한이 있는 고유재산이므로 상속재산의 범위에 포함되지 않는다.³⁸²⁾

4. 상속재산분할의 기준 및 평가시기

가. 일반적 기준

상속재산의 분할기준에 대하여 법에 직접적인 규정이 없지만 상속재산은 피상속인(망인)과 공동상속인 사이의 친족적 유대관계가 강하므로 이들 사이의 공평하고 평등한 재산 분할이 요구된다. 따라서 공동상속인의 의사나 희망, 상속재산의 종류·성질·가액·이용

380) 대법원 1982. 08. 24. 선고 81누162 판결.

381) 대법원 1994. 03. 22. 선고 93누19535 판결.

382) 대법원 2019. 5. 17.자 2017스516, 517 결정.

관계, 상속인의 연령 · 직업 · 심신상태 · 생활상태 · 재산의 관리능력, 망인의 생전의 의사, 공동상속인 사이의 분할에 관한 협의 경과 등 일체의 사정을 참작하여야 한다.³⁸³⁾

나. 평가시기

일부 다른 견해가 있으나 기여분이나 특별수익 등의 산정을 통한 구체적 상속분을 정하기 위한 상속재산의 평가는 상속개시를 기준으로 하고, 현실적으로 상속재산을 분할하기 위한 상속재산의 평가는 상속재산분할 시를 기준으로 하여 평가하여야 한다는 것이 다수설 및 판례이다.³⁸⁴⁾

공동상속인 중에 피상속인으로부터 재산의 증여 또는 유증 등의 특별수익을 받은 자가 있는 경우에는 이러한 특별수익을 고려하여 상속인별로 고유의 법정상속분을 수정하여 구체적인 상속분을 산정하게 되는데, 이러한 구체적 상속분을 산정함에 있어서는 상속개시 시를 기준으로 상속재산과 특별수익재산을 평가하여 이를 기초로 하여야 할 것이고, 다만 법원이 실제로 상속재산분할을 함에 있어 분할의 대상이 된 상속재산 중 특정의 재산을 1인 및 수인의 상속인의 소유로 하고 그의 상속분과 그 특정의 재산의 가액과의 차액을 현금으로 정산할 것을 명하는 방법(소위 대상분할의 방법)을 취하는 경우에는, 분할의 대상이 되는 재산을 그 분할 시를 기준으로 하여 재평가하여 그 평가액에 의하여 정산을 하여야 한다.³⁸⁵⁾

상속재산 및 특별수익재산 가액의 평가는 상담개시 당시의 시가로 하고, 특별수익 중 현금의 상속개시 당시의 평가액은 수증 당시의 금액에 소비자 물가지수를 참작하여 산정하여야 한다.³⁸⁶⁾

다. 평가방법

상속재산 평가의 방법에 대해서 특별한 규정이 없으므로 객관성이 담보되는 한 가정법원이 적당하다고 인정되는 방법에 의하면 된다. 부동산에 관하여는 공시지가나 기준시가 또는 과세표준 등에 의할 수도 있으나, 공동상속인 사이에 가액에 관한 다툼이 있거나 감정에 의할 것을 희망하고 있는 등의 경우에는 전문가의 감정에 의하는 것이 바람직하다.³⁸⁷⁾

383) 법원행정처, 법원실무제요(가사Ⅱ), 618면.

384) 서울가정법원, “실무연구Ⅵ”, 167면.

385) 대법원 1997. 03. 21. 자 선고 96스62 결정.

386) 서울고등법원 1991. 01. 18. 선고 89르2400 판결: 상고기각.

5. 상속재산의 분할방법

가. 상속재산분할의 기준이 되는 구체적 상속분을 산정하는 방법

상속재산분할은 법정상속분이 아니라 특별수익(피상속인의 공동상속인에 대한 유증이나 생전 증여 등)이나 기여분에 따라 수정된 구체적 상속분을 기준으로 이루어진다.

구체적 상속분을 산정함에 있어서는, 상속개시 당시를 기준으로 상속재산과 특별수익재산을 평가하여 이를 기초로 하여야 하고, 공동상속인 중 특별수익자가 있는 경우 구체적 상속분 가액의 산정을 위해서는, 피상속인이 상속개시 당시 가지고 있던 재산 가액에 생전 증여의 가액을 가산한 후, 이 가액에 각 공동상속인별로 법정상속분율을 곱하여 산출된 상속분의 가액으로부터 특별수익자의 수증재산인 증여 또는 유증의 가액을 공제하는 계산 방법에 의한다. 이렇게 계산한 상속인별 구체적 상속분 가액을 전체 공동상속인들 구체적 상속분 가액 합계액으로 나누면 상속인별 구체적 상속분 비율, 즉 상속재산분할의 기준이 되는 구체적 상속분을 얻을 수 있다.

한편 위와 같이 구체적 상속분 가액을 계산한 결과 공동상속인 중 특별수익이 법정상속분 가액을 초과하는 초과특별수익자가 있는 경우, 그러한 초과특별수익자는 특별수익을 제외하고는 더 이상 상속받지 못하는 것으로 처리하되(구체적 상속분 가액 0원), 초과특별수익은 다른 공동상속인들이 그 법정상속분율에 따라 안분하여 자신들의 구체적 상속분 가액에서 공제하는 방법으로 구체적 상속분 가액을 조정하여 위 구체적 상속분 비율을 산출함이 바람직하다. 결국 초과특별수익자가 있는 경우 그 초과된 부분은 나머지 상속인들의 부담으로 돌아가게 된다(대법원 2022. 6. 30.자 2017스98, 99, 100, 101 결정).

나. 유언에 의한 분할

(1) 개 설

피상속인은 유언으로 상속재산의 분할방법을 정하거나 이를 정할 것을 제3자에게 위탁할 수 있고, 더 나아가 상속개시의 날로부터 5년을 초과하지 아니하는 기간 내에서 상속재산의 분할 자체를 금지할 수 있다(민법 제1012조).

(2) 지정분할과 위탁지정분할

피상속인은 유언으로 상속재산의 분할방법을 정하거나 이를 정할 것을 제3자에게 위탁

387) 서울가정법원, “실무연구VI”, 167면.

할 수 있다(민법 제1012조). 지정할 분할방법에는 현물분할이거나 가액분할이거나 상관없다. 가령 피상속인이 유언으로 장남 A에게는 아파트 1채와 주식 10,000주를 차남에게는 대지 1,000제곱미터를, 장녀에게는 예금증서를 주라고 할 수 있다. 피상속인의 유언에 의한 지정분할은 실제로 유증을 했는지 아니면 재산의 분할을 지정했는지 피상속인의 의사가 명확하게 하지 않으면 구별하기 힘들다.³⁸⁸⁾

(3) 지정분할과 위탁지정분할을 할 경우 법정상속분을 넘는 지정이 가능한가?

(가) 초과지정부정설

위탁 받은 제3자의 지정은 각 공동상속인의 상속분에 따른 것이어야 한다고 한다.³⁸⁹⁾

(나) 초과지정긍정설

위탁자의 법정상속분을 넘는 지정도 유효하다.³⁹⁰⁾

다. 협의에 의한 분할

(1) 의 의

공동상속인은 유언에 의한 분할방법의 지정이 없거나 분할방법 지정의 위탁이 없는 경우, 또한 유언이 무효인 경우, 지정위탁을 받은 사람이 지정을 하지 않는 경우, 유언에 의하여 분할금지가 없는 경우 등 요건이 갖추어지면 언제든지 협의에 의하여 상속재산을 분할할 수 있다(민법 제1013조 제1항).

(2) 협의분할에 참가할 수 있는 자

분할의 협의는 공동상속인 간에 행해지는 일종의 계약이므로 공동상속인 전원이 참가하여야 한다. 따라서 일부 상속인만으로 한 협의분할은 무효이다.³⁹¹⁾

포괄수증자, 분할 전의 상속분의 양수인도 협의의 당사자이다. 상속재산분할협의를 이미 상속을 포기한 자가 참여하였다 하더라도 그 분할협의의 내용이 이미 포기한 상속지분을 다른 상속인에게 귀속시킨다는 것에 불과하여 나머지 상속인들 사이의 상속재산분할에

388) 대법원 2001. 06. 29. 선고 2001다28299 판결(피상속인은 유언으로 상속재산의 분할방법을 정할 수는 있지만, 생전행위에 의한 분할방법의 지정은 그 효력이 없어 상속인들이 피상속인의 의사에 구속되지는 않는다).

389) 김주수, 앞의 책, 557면.

390) 박윤직, 앞의 책(상속법), 246면.

391) 대법원 1995. 04. 07. 선고 93다54736 판결.

관한 실질적인 협의에 영향을 미치지 않은 경우라면 그 상속재산분할협이는 효력이 있다고 볼 수 있다.³⁹²⁾

(가) 태아인 경우

판례가 정지조건설 입장에서 태아의 상속재산분할 협의를 인정하지 않으므로 살아서 출생할 때까지 상속인의 수와 상속분이 분명하지 않으므로 태아가 출생할 때까지 기다려서 분할하는 것이 타당하다.³⁹³⁾

(나) 공동상속인이 제한능력자인 경우

법정대리인이 협의에 참가하거나 미성년자와 그 법정대리인인 친권자가 공동상속인인 경우 분할협이는 이해상반되는 행위에 해당하므로 친권자가 미성년자들의 특별대리인을 선임하지 아니하고서 한 상속재산분할의 협의는 무효이다.³⁹⁴⁾

(다) 상속인의 지위를 상실할 우려가 있는 자

상속결격, 친생부인, 친생자관계부존재, 인지무효, 혼인무효, 입양무효 등의 소가 제기되어 있는 경우 진행하되 상속회복청구로 하여야 한다는 견해³⁹⁵⁾와 담보조건 등으로 인정한다는 조건부진행설,³⁹⁶⁾ 확정판결 시까지 금지한다는 설³⁹⁷⁾이 대립하고 있다. 생각건대 실제로 협의분할이 성립되기 어렵고 또한 판결의 확정으로 상속인의 자격을 잃게 되면 분할협이가 무효로 되므로 판결이 확정될 때까지 기다려 협의하는 것이 타당하다.

(라) 상속인의 지위를 주장하는 자

인지청구, 이혼무효, 파양무효, 부를 정하는 소 등을 제기하고 있는 경우 일단 이를 제외하고는 분할하며, 추후 상속인으로 확정되더라도 그 협의는 유효하고, 다만 그들에게 가액 지급청구권이 인정된다(민법 제1014조).

392) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2007다30447 판결

393) 박윤직, 앞의 책(상속법), 141면; 김주수·김상용, 앞의 책, 604면; 박병호, 앞의 책, 379면; 이경희, 앞의 책, 442면; 송덕수, 앞의 책, 1916면.

394) 대법원 1987. 03. 10. 선고 85므80 판결.

395) 김용한, 앞의 책, 345면.

396) 김주수·김상용, 앞의 책, 602면.

397) 박윤직, 앞의 책, 142면; 박병호, 앞의 책, 380면; 이경희, 앞의 책, 442면; 송덕수, 앞의 책, 1916면.

(3) 협의방법

분할협의는 상속인 전원이 참석하여 합의를 하거나 한 사람이 원안을 만들어 승낙을 받는 형태로 처리한다. 협의에 의한 상속재산의 분할은 공동상속인 전원의 동의가 있어야 유효하고 공동상속인 중 1인의 동의가 없거나 그 의사표시에 대리권의 흠결이 있다면 분할은 무효이다.³⁹⁸⁾ 반드시 한 자리에서 이루어질 필요는 없고 순차적으로 이루어질 수도 있으며,³⁹⁹⁾ 상속인 중 한사람이 만든 분할 원안을 다른 상속인이 후에 돌아가며 승인하여도 무방하다.⁴⁰⁰⁾ 또한 그 분할되는 몫은 반드시 각자의 법정상속분에 따르지 않아도 된다.

한편 상속인 중에 미성년자와 그 친권자가 있는 경우에는 친권자가 그 미성년자의 주소를 관할하는 가정법원에 특별대리인선임신청을 하여 그 선임된 특별대리인과 분할의 협의를 하여야 한다(민법 제921조, 대법원 2001. 6. 29. 2001다28299).

대체적으로 “상속재산분할합의서”를 작성하는 것이 일반적이다. 이는 사후 상속재산에 대해 등기를 하거나 명의변경 또는 이해관계인에게 통지 등을 할 때 필요로 하기 때문이다. 작성방법은 아래의 [서식]을 참조한다.

[서식] 상속재산분할협의서

상속재산분할 협의서

서기 20〇〇년 10월 13일 서울특별시 서초구 양재로 1234 망 홍길동의 사망으로 인하여 개시한 상속에 있어 공동 상속인 성춘향, 동 홍대한, 동 홍민국, 동 홍만세는 다음과 같이 상속재산을 분할 협의한다.

- 다 음 -

1. 상속재산 중 별지 목록 기재 부동산은 성춘향의 소유로 한다.
2. 상속재산 중 주식회사 좋은 한국의 보통주식 10,000주 중 홍대한은 5,000주, 홍민국과 홍만세는 각 2,500주의 소유로 한다.
3. 상속재산 중 국민은행 양재동지점(계좌번호 : 1234-5678)에 예금된 금 1억 원 중 성춘향은 5,000만 원, 홍민국과 홍만세는 각 2,500만 원의 소유로 한다.

398) 대법원 1987. 3. 10. 선고 85므80 판결

399) 대법원 2001. 11. 27. 선고 2000두9731 판결

400) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2003다65438,65445 판결

위 협의를 증하기 위하여 이 협의서 4통을 작성하고 아래와 같이 기명날인 하여 각자 1통씩 보유한다.

20〇〇. 2. 13.

- 상속인 1. 성 춘 향 (주민등록번호 :)
 서울 〇〇구 〇〇대로〇〇길 〇〇(〇〇동)
2. 홍 대 한 (주민등록번호 :)
 서울 〇〇구 〇〇대로〇〇길 〇〇(〇〇동)
3. 홍 민 국 (주민등록번호 :)
 서울 〇〇구 〇〇대로〇〇길 〇〇(〇〇동)
4. 홍 만 세 (주민등록번호 :)
 서울 〇〇구 〇〇대로〇〇길 〇〇(〇〇동)

(4) 분할방법

분할방법은 아무런 제한이 없다. 따라서 현물분할, 공동소유로 하는 분할, 대상분할, 환가분할, 경매분할, 상속재산의 일부만을 분할하고 다른 것은 공동소유로 둔다는 등으로 하여도 상관없다.

현물분할이라 함은 상속재산에 속하는 물건을 그대로의 형태로 상속인에게 나누는 방법을 말하고, 대상분할이라 함은 분할의 대상이 된 상속재산 중 특정의 재산을 1인 또는 수인의 상속인의 소유로 하고 그의 상속분 및 기여분과 그 특정재산의 가액과의 차액을 현금으로 정산할 것을 명할 수 있는 것을 말한다. 경매에 의한 가액분할은 다른 적절한 분할방법이 없는 경우에 최후로 선택할 수 있는 방법이다.

가정법원이 상속재산분할을 함에 있어 분할 대상이 된 상속재산 중 특정 재산을 일부 상속인 소유로 현물분할 한다면, 전체 분할 대상 재산을 분할 시 기준으로 평가하여, ① 특정 재산 가액이 그의 구체적 상속분에 따른 취득가능 가액을 초과하는 상속인이 있는 경우 차액을 정산하도록 하여야 하고(구체적 상속분을 산정함에 있어 유증이나 생전 증여 등으로 인한 초과특별수익과 달리, 산정된 구체적 상속분에 따른 취득가능 가액을 초과하여 분할받게 되는 부분은 다른 상속인들에게 정산해야 한다), ② 특정 재산 가액이 그의 구체적 상속분에 따른 취득가능 가액을 초과하지 않을 경우에도 위와 같은 현물분할을

반영하여 상속인들 사이의 지분율을 다시 산정해서 남은 분할 대상 상속재산은 수정된 지분율로 분할해야 한다.

이를 위해 전체 분할 대상 상속재산의 분할 시 기준 평가액에 상속인별 구체적 상속분을 곱하여 산출된 상속인별 취득가능 가액에서 각자 소유로 하는 특정 재산의 분할 시 기준 평가액을 공제하는 방법으로 구체적 상속분을 수정한 지분율을 산정할 수 있다(대법원 2022. 6. 30.자 2017스98, 99, 100, 101 결정).

상속재산 및 특별수익재산 가액의 평가는 상담개시 당시의 시가로 하고, 특별수익 중 현금의 상속개시 당시의 평가액은 수증 당시의 금액에 소비자 물가지수를 참작하여 산정하여야 한다.⁴⁰¹⁾

공동상속인 사이의 상속지분의 양도는 공동상속인 전원의 약정에 기한 경우, 이를 상속재산의 협의분할의 취지로 한 것으로 볼 수 있다.⁴⁰²⁾

(5) 분할과 상속분의 관계

협의분할의 경우에는 반드시 법정상속분에 따라서 분할하여야 하는 것은 아니다. 그러므로 1인이 법정지분을 초과하는 재산을 취득한 경우 상속인 사이에 증여로 볼 것이지,⁴⁰³⁾ 상속개시 당시에 피상속인으로부터 승계 받은 것으로 볼 것인지 다툼이 있으나, 다수설⁴⁰⁴⁾과 판례⁴⁰⁵⁾는 증여로 보지 않는다.

(6) 협의분할의 무효 · 취소

무자격자가 분할협약에 참가한 경우는 물론 공동상속인으로서 협의에서 제외된 경우에는 제외 그 자체가 분할협약무효의 원인이 되며 제외된 상속인은 그의 상속인자격이 부인되어 있지 않는 한 상속회복청구를 할 것이 아니라 분할무효확인 및 재분할을 청구할 수 있다.⁴⁰⁶⁾ 분할협약이 무효로 되거나 취소된 경우 분할에 의한 동산을 취득한 제3자는 선의 취득으로 보호될 수 있으며(민법 제249조), 부동산인 경우에는 취득지분에 대해서는 유효하므로,⁴⁰⁷⁾ 제외된 자는 자기의 지분에 관해서는 무효를 주장할 수 있고, 그 주장은 상속회

401) 서울고등법원 1991. 01. 18. 선고 89르2400 판결.

402) 대법원 1995. 09. 15. 선고 94다23067 판결.

403) 이경희, 앞의 책, 450면.

404) 박윤직, 앞의 책(상속법), 138면; 김주수·김상용, 앞의 책, 607-608면; 송덕수, 앞의 책, 1916면; 지원림, 앞의 책, 2047면.

405) 대법원 2002. 07. 12. 선고 2001두441 판결.

406) 김형배, 앞의 책, 336면; 법원행정처, 『상속등기실무』, 121면.

407) 대법원 1965. 08. 24. 선고 65다1086 판결.

복청구에 의해서가 아니라 통상의 물권적 청구권의 행사에 의해서 실현해야 할 것이라는 견해와 상속회복청구권의 문제로 처리하려는 견해⁴⁰⁸⁾가 있다.

(7) 협의분할 후 새로운 분할협의

상속재산 분할협의는 공동상속인들 사이에 이루어지는 일종의 계약으로서, 공동상속인들은 이미 이루어진 상속재산 분할협의의 전부 또는 일부를 전원의 합의에 의하여 해제한 다음 다시 새로운 분할협의를 할 수 있고, 상속재산 분할협의를 합의해제 되면 그 협의에 따른 이행으로 변동이 생겼던 물권은 당연히 그 분할협의를 없었던 원상태로 복귀하지만, 민법 제548조 제1항 단서의 규정상 이러한 합의해제를 가지고서는, 그 해제 전의 분할협의로부터 생긴 법률효과를 기초로 하여 새로운 이해관계를 가지게 되고 등기·인도 등으로 완전한 권리를 취득한 제3자의 권리를 해하지 못한다.⁴⁰⁹⁾

(8) 협의의 상속재산분할과 채권자취소권

상속재산분할협의는 그 성질상 재산을 목적으로 하는 법률행위이므로 채권자취소권 행사의 대상이 될 수 있다.⁴¹⁰⁾

상속이 개시되어 공동상속인 사이에 잠정적 공유가 된 상속재산에 대하여 그 전부 또는 일부를 각 상속인의 단독소유로 하거나 새로운 공유관계로 이행시킴으로써 상속재산의 귀속을 확정시키는 것으로 그 성질상 재산을 목적으로 하는 법률행위이므로 사해행위취소권 행사의 대상이 될 수 있고,⁴¹¹⁾ 한편 채무자가 자기의 유일한 재산인 부동산을 매각하여 소비하기 쉬운 금전으로 바꾸거나 타인에게 무상으로 이전하여 주는 행위는 특별한 사정이 없는 한 채권자에 대하여 사해행위가 되는 것이므로,⁴¹²⁾ 이미 채무초과 상태에 있는 채무자가 상속재산의 분할협의를 하면서 유일한 상속재산인 부동산에 관하여는 자신의 상속분을 포기하고 대신 소비하기 쉬운 현금을 지급받기로 하였다면, 이러한 행위는 실질적으로 채무자가 자기의 유일한 재산인 부동산을 매각하여 소비하기 쉬운 금전으로 바꾸는 것과 다르지 아니하여 특별한 사정이 없는 한 채권자에 대하여 사해행위가 된다고 할 것이며, 이와 같은 금전의 성격에 비추어 상속재산 중에 위 부동산 외에 현금이 다소

408) 김주수, 앞의 책, 555면.

409) 대법원 2004. 07. 08. 선고 2002다73203 판결.

410) 이경희, 앞의 책, 451면; 송덕수, 앞의 책, 1917면; 지원림, 앞의 책, 2047면.

411) 대법원 2001. 02. 09. 선고 2000다51797 판결 참조.

412) 대법원 2001. 04. 24. 선고 2000다41875 판결; 대법원 2002. 06. 11. 선고 2002다17937 판결.

있다 하여도 마찬가지로 보아야 할 것이다.⁴¹³⁾

라. 가정법원에 의한 분할청구

(1) 분할청구

공동상속인 사이에 상속재산분할의 협의가 이루어지지 않을 경우, 각 공동상속인은 가정법원에 상속재산분할을 청구할 수 있다. 이 경우에는 먼저 법원에 조정을 신청하여야 하고 조정이 성립되지 않으면 심판을 청구할 수 있다. 여기에서 ‘협의를 성립되지 아니한 때’에는 분할방법에 관해서 뿐만 아니라 분할여부에 관하여 의견이 일치하지 않는 경우도 포함된다. 이런 경우에는 각 공동상속인은 먼저 가정법원에 조정을 신청하여야 하며(가사소송법 제2조 제1항 마류사건 제10호), 조정이 성립되지 않으면 심판을 청구할 수 있는데, 심판에 의한 분할방법은 현물분할을 원칙으로 하며, 가정법원은 현물로 분할할 수 없거나 분할로 인하여 현저히 그 가액이 감소될 염려가 있는 때에는 물건의 경매를 명하기도 한다.

(2) 분할방법

분할의 형태 현물분할, 경매에 의한 가액분할, 상속재산 중 특정의 재산을 1인 또는 수인의 상속인의 소유로 하고 그의 상속분 및 기여분과 그 특정의 재산의 가액의 차액을 현금으로 정산하는 것(차액정산에 의한 현물분할, 규칙 제115조 제2항)의 3가지가 있다. 심판이 확정되면 분할방법으로 현물분할 할 것이냐 아니면 환가분할로 할 것이냐는 법원의 재량으로 결정한다.⁴¹⁴⁾

민법 제269조 제2항 소정의 대금분할을 해야 할 경우인 분할로 인하여 현저히 그 가액이 감소될 염려가 있는 때라 함은 그 공유물 전체의 교환가치가 현물분할로 인하여 현저하게 감소될 경우뿐만 아니라, 공유자들에게 공정한 분할이 이루어지지 아니하여 그중의 한사람이라도 현물분할에 의하여 단독으로 소유하게 될 부분의 가액이 공유물 분할 전의 소유지분가액보다 현저하게 감소될 경우도 이에 포함된다 할 것이므로 비록 형식적으로는 현물분할이 가능하다 하더라도 공유물의 위치, 면적과 주변도로상황, 사용가치, 가격, 각 공유자의 소유지분 비율에 따른 공평한 분할이 이루어질 수 없는 경우에는 현물 분할방법에 의한 것이 아니라 대금분할방법으로 그 공유물을 분할하여야 할 것이다.⁴¹⁵⁾

413) 대법원 2013. 06. 13. 선고 2013다2788 판결; 대법원 2008. 03. 13. 선고 2007다73765 판결.

414) 서울고등법원 1979. 06. 29. 선고 79나130 판결.

415) 대법원 1985. 02. 26. 선고 84다카1194 판결.

(3) 상속재산의 경매를 명한 상속재산분할심판이 확정된 경우 상속재산에 관한 물권 변동의 효력이 발생하는지 여부

가정법원의 심판으로 경매를 명한 상속재산분할심판이 확정되면 심판의 당사자는 이 심판에 기하여 상속재산에 대하여 경매를 신청하고 경매에 따른 매각대금을 수령할 권리가 있으나 상속재산분할심판에서 정한 구체적 상속분에 따라 물권변동의 효력이 발생하는 것은 아니라고 할 것이므로, 구체적 상속분에 따라 이 사건 부동산에 관한 소유권을 취득한 것은 아니다.⁴¹⁶⁾

(4) 분할청구의 시기

우리 민법이 한정승인 절차가 상속재산분할 절차보다 선행하여야 한다는 명문의 규정을 두고 있지 않고, 공동상속인들 중 일부가 한정승인을 하였다고 하여 상속재산분할이 불가능하다거나 분할로 인하여 공동상속인들 사이에 불공평이 발생한다고 보기 어려우며, 상속재산분할의 대상이 되는 상속재산의 범위에 관하여 공동상속인들 사이에 분쟁이 있을 경우에는 한정승인에 따른 청산절차가 제대로 이루어지지 못할 우려가 있는데 그럴 때에는 상속재산분할청구 절차를 통하여 분할의 대상이 되는 상속재산의 범위를 한꺼번에 확정하는 것이 상속채권자의 보호나 청산절차의 신속한 진행을 위하여 필요하다는 점 등을 고려하면, 한정승인에 따른 청산절차가 종료되지 않은 경우에도 상속재산분할청구가 가능하다(대법원 2014. 7. 25.자 2011스226 결정).

6. 상속재산 분할의 효과

가. 상속재산분할의 소급효

(1) 소급효

(가) 상속재산의 분할은 상속개시 된 때에 소급하여 그 효력이 있다(민법 제1015조 본문). 즉, 상속재산을 피상속인으로부터 상속인들 각자가 직접 상속하는 것이 되어 그 재산에 대해서 상속인들의 공유상태는 존재하지 않았던 것으로 된다. 공유물분할에는 이전 시부터 효과가 발생하는 이전주의를 택하고 있는 반면 상속재산분할은 선언주의를 채택하고 있다. 소급효는 현물분할의 경우에만 인정되고, 대금분할이나 가격배상의 경우에는 인정되지 않는다는 데 이설이 없다.⁴¹⁷⁾ 가령 현물분할의 경우 상속재산인 부동산·동산 및

416) 대법원 2012. 12. 27. 선고 2010다10108 판결.

채권을 3인의 상속인 갑·을·병이 공유하고 있다가 분할에 의하여 갑이 부동산, 을이 동산, 병이 채권을 가지게 되면 그 결과 상속개시 처음부터 갑이 부동산 을이 동산 그리고 병이 채권을 각각 직접 피상속인으로부터 상속한 것이 되어 그 재산에 대하여 갑·을·병 3인의 공유 상태가 되지 않았던 것으로 된다.

(나) 민법 제1015조에서 상속재산의 분할은 상속개시 된 때에 소급하여 그 효력이 있다고 규정하고 있는 취지는 분할에 의하여 각 공동상속인에게 귀속되는 재산이 상속개시당시에 이미 피상속인으로부터 직접 분할 받은 자에게 승계된 것을 의미하므로 분할에 의하여 공동상속인 중의 1인이 고유의 상속분을 초과하는 재산을 취득하게 되었다 하더라도 공동상속인 상호간에 상속분의 이전이 생기는 것이 아니다.⁴¹⁸⁾

(다) 상속재산에 관하여 공동상속인 간에 협의분할이 이루어짐으로써 공동상속인 중의 1인이 고유의 상속분을 초과하는 재산을 취득하게 되었다 하더라도 상속재산의 분할은 상속개시 시에 소급하여 그 효력이 있으며, 따라서 이는 상속개시 당시에 피상속인으로부터 직접 승계 받은 것으로 보아야 한다.⁴¹⁹⁾ 즉, 초과부분은 다른 공동상속인으로부터 증여 받은 것이 아니고 피상속인으로부터 직접승계 받은 것이다.

(라) 부동산소유권이전등기의무자는 특별한 사정이 없는 한 등기부상의 명의인이라고 할 것인바, 피상속인으로부터 매수한 부동산에 관하여 그 공동상속인들의 협의분할에 의하여 그중 1인만이 단독으로 그 상속등기까지 마쳤다면 협의분할의 소급효에 의하여 나머지 공동상속인들은 이 사건 부동산을 상속한 것이 아니라 할 것이고 현재 등기부상의 등기명의자가 아니어서 등기의무자가 될 수도 없다 할 것이므로 그에 대한 지분소유권이전등기 절차를 이행할 의무가 없다.⁴²⁰⁾

(2) 소급효와 등기

상속재산분할에 의하여 어떤 공동상속인이 특정부동산을 취득한 경우 피상속인으로부터 직접 이전등기를 할 수 있고, 아니면 공동상속에 의한 공유등기를 한 뒤에 이전등기를 하여도 무방하다고 한다.⁴²¹⁾

417) 송덕수, 앞의 책, 1921면.

418) 대법원 1988. 02. 23. 선고 87누1022 판결.

419) 대법원 1992. 10. 27. 선고 92다32463 판결; 대법원 1990. 11. 13. 선고 88다카24523, 24530 판결; 대법원 1992. 03. 27. 선고 91누7729 판결.

420) 대법원 1991. 08. 27. 선고 90다8237 판결; 대법원 1989. 09. 12. 선고 88다카5836 판결.

421) 박윤직, 앞의 책(상속법), 151면; 김주수·김상용, 앞의 책, 609면; 송덕수, 앞의 책, 1922면; 지원림, 앞의 책, 2051면.

공동상속인이 상속재산을 공유하는 동안 생긴 과실을 상속재산에 포함되어 분할의 대상에 된다는데 이설이 없다.⁴²²⁾

(3) 소급효 제한

분할의 소급효는 제3자의 권리를 해하지 아니한다(민법 제1015조 단서). 제3자의 선의, 악의는 묻지 않는다. 다만, 제3자의 권리는 권리변동의 효력발생요건(민법 제186조, 제187조)과 대항요건(민법 제450조)을 갖추고 있어야 한다.

상속재산 협의분할에 의하여 소유권이전등기가 경료된 경우 협의분할 이전에 피상속인의 장남으로부터 토지를 매수하였을 뿐 등기를 경료하지 아니한 자나 그 상속인들이 민법 제1015조 단서 소정의 상속재산분할의 소급효가 제한되는 ‘제3자’에 해당하는지 여부에 대하여 판례⁴²³⁾는 제3자에 해당하지 않는다 하여 상속지분에 대한 협의분할을 무효로 주장할 수 없다고 한다.

상속재산분할의 소급효가 제한되는 ‘제3자’는 상속재산분할의 소급효를 인정하여 공동상속인이 분할 내용대로 상속재산을 피상속인이 사망한 때에 바로 피상속인으로부터 상속한 것으로 보면서도, 상속재산분할 전에 이와 양립하지 않는 법률상 이해관계를 가진 제3자에게는 상속재산분할의 소급효를 주장할 수 없도록 함으로써 거래의 안전을 도모하고자 한 것이다. 이때 민법 제1015조 단서에서 말하는 제3자는 일반적으로 상속재산분할의 대상이 된 상속재산에 관하여 상속재산분할 전에 새로운 이해관계를 가졌을 뿐만 아니라 등기, 인도 등으로 권리를 취득한 사람을 말한다.⁴²⁴⁾

나. 공동상속인의 담보책임

(1) 매도인과 동일한 담보책임

공동상속인은 다른 공동상속인이 분할로 인하여 취득한 재산에 대하여 그 상속분에 응하여 매도인과 같은 담보책임이 있다(민법 제1016조). 가령, 피상속인과 그 처는 자녀 A, B, C를 두고 사망하였다. 상속재산은 부동산(아파트 1채), 동산(고가 그림 등), 채권(주식, 예금증서 등)이 있으나 피상속인 등은 상속재산에 대하여 아무런 유언도 남기지 않았다. 따라서 상속재산은 4인의 공동소유(공유)가 되므로 상속재산을 분할하기로 합의를 하고 부동산(약 1억 원)은 장남 A, 주식(약 1억 원)은 차남 B, 예금증서(약 1억 원)는

422) 송덕수, 앞의 책, 1922면.

423) 대법원 1992. 11. 24. 선고 92다31514 판결.

424) 대법원 2020. 8. 13. 선고 2019다249312 판결.

장녀 C의 소유로 각자 명의변경을 하였다. 그러나 C가 상속받은 재산에 1500만 원의 하자가 있는 경우에 을이 받은 1500만 원의 손해는 A, B, C가 상속분에 응하여 매도인과 같은 담보책임이 있다. 따라서 C가 받은 1500만 원의 손해는 A, B, C가 1 : 1 : 1의 비율로 부담되고 C는 A에게 500만 원, B에게 500만 원의 상환을 청구할 수 있다. 그런데 해제에 의하여 재분할하는 경우에도 인정할 것인가 견해의 대립이 있으나, 분할의 목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 허용된다는 설이 타당하다.⁴²⁵⁾

(2) 상속채무자의 자력에 대한 담보책임

공동상속인은 다른 상속인이 분할로 인하여 취득한 채권에 대하여 분할 당시의 채무자의 자력을 담보한다(민법 제1017조 제1항). 가령 피상속인(甲)은 처(乙), 자녀 A, B, C를 두고 사망하였다. 상속재산은 부동산(아파트 1채), 동산(고가 그림 등), 채권(주식, 예금증서 등)이 있다. 피상속인은 유언으로 상속재산에 대하여 아무 말이 없었다. 따라서 상속재산은 4인의 공동소유(공유)가 된다. 그러나 상속재산의 분할로 부동산(약 1억 원)은 피상속인의 처(乙), 동산(약 1억 원)은 장남 A, 주식(약 1억 원)은 차남 B, 예금증서(약 5천만 원)는 장녀 C가 갖기로 서로 합의를 하고 각자 소유로 명의변경을 하였다. 그러나 장녀 C가 은행의 파산으로 채권을 회수할 수 없는 경우에는 다른 공동상속인 甲의 처(乙), A, B는 그 상속분에 응하여 분할 당시의 채무자의 자력을 담보한다. 그러나 분할 당시 이미 변제기에 있는 채권에 대하여는 분할 당시의 채무자의 자력을 담보하지만, 분할 당시 변제기에 달하지 아니한 채권이나 정지조건이 있는 채권에 대하여는 변제를 청구할 수 있는 때의 채무자의 자력을 담보한다(민법 제1017조 제2항).

(3) 무자력공동상속인의 담보책임

담보책임이 있는 공동상속인 중에 상환의 자력이 없는 자가 있는 때에는 그 부담부분은 구상권자와 자력이 있는 다른 공동 상속인이 그 상속분에 응하여 부담한다(민법 제1018조). 가령 甲(부)과 乙(모)의 사망으로 상속재산(약 3억 원)은 자녀 A, B, C가 공동소유로 상속받는다. 따라서 공동상속인이 1억 원씩 상속재산을 분할하였다. 그러나 A가 상속받은 재산의 하자가 1,200만 원인 경우, 구상권자인 A가 B, C, D에게 각각 300만 원씩 청구하였다. 즉, A, B, C, D가 각자 300만 원씩 부담하게 된다. 그런데 B가 자력이 없다면, 즉 상속재산의 분할 후 B는 주식으로 재산을 모두 탕진한 경우, 구상권자인 A와 자력이 있는 C, D가 그 상속분에 응하여 100만 원씩 더 부담하게 된다. A, C, D의 1,200만 원에 대한

425) 김주수·김상용, 앞의 책, 619면; 지원림, 앞의 책, 2056면.

하자 손해액은 B의 무자력으로 인해 A는 400만 원, C는 400만 원, D는 400만 원을 부담한다. 그러나 구상권자의 과실로 인하여 상환을 받지 못한 때에는 다른 공동상속인에게 부담을 청구하지 못한다(민법 제1018조 단서). 위 사례에서 A가 제때에 B, C, D에게 청구하였다면 변제를 받을 수 있었으나 그것을 게을리 하여 B의 무자력으로 변제 받지 못하게 되었다면 A는 C, D에게 부담을 청구하지 못한다.

7. 상속재산분할 심판청구

[가사소송법 제2조 제1항 2.나.10), 마류 가사비송사건]

가. 심판분할의 전제

상속재산의 분할을 실행하려면 먼저 그 전제로서 상속인을 확정하고, 상속재산의 범위 및 그 액을 확정하지 않으면 안 된다.

상속인이 누구인지는 대개 가족관계등록부의 기재에 의하여 명백히 알 수 있으나, 분명하지 않는 경우도 있다.

상속인이 상속개시 당시부터 행방불명인 경우에는 부재자재산관리인을 선임(민법 제22조)하여 분할하여야 유효하다. 생사불명의 상태가 일정기간 계속한 때에는 실종선고의 절차를 밟아야 할 것이다. 또한 인지무효·혼인무효·이혼무효·입양무효·파양무효 등의 소가 계속 중인 경우에는 재판의 확정을 기다려서 분할심판을 하는 것이 바람직하다. 이에 비하여 친생부인, 인지취소, 인지청구, 이혼취소, 파양취소 등과 같이 확정판결에 의하여 비로소 신분관계에 변동이 생기는 사항을 주장하는 경우에는 그 확정판결이 없는 한 그 주장을 고려할 것이 아니다. 그밖에 상속인의 결격사유의 존부, 상속분 양도 또는 상속포기의 유무나 효력유무 등은 상속재산분할심판절차에서 선결문제로 심리, 판단할 수 있다고 할 것이다. 또 어느 재산이 피상속인의 상속재산인지 공동상속인 또는 제3자의 소유인지에 관한 다툼은 원칙적으로 소송사항이다. 따라서 제3자 소유명의로 등기 등이 이루어져 있는 재산은 그 제3자에 대한 관계에서 확정판결에 의하여 상속재산임이 확정되었거나 그 제3자가 상속재산분할의 심판절차에 참가하여 상속재산임을 인정하였다는 등의 사정이 없는 한 가정법원이 그 소유권의 귀속문제를 스스로 판단하여 분할의 대상으로 삼을 수는 없다. 다만, 공동상속인 중의 1인 또는 수인의 소유명의 등기 등이 이루어져 있는 재산은 심판절차에서 그 명의인이 상속재산임을 인정하는 등, 공동상속인 간에 그 재산을 상속재산으로 한다는 합의가 있는 때에는 분할의 대상으로 할 수 있다고 할 것이다.⁴²⁶⁾ 또한 피상속인이

유언으로 상속개시일로부터 5년을 초과하지 아니하는 기간 동안 상속재산분할을 금지한 때에는 상속재산분할을 청구할 수 없다. 공동상속인 전원의 협의로 분할을 금지하기로 한 때에도 같다. 다만, 어느 경우에도 그 금지기간 내에 상속재산을 분할해야 할 사정변경이 생긴 때에는 분할금지에 불구하고 상속재산분할을 청구할 수 있다는 견해가 다수설이다.⁴²⁷⁾

나. 상속재산분할 심판청구 절차

(1) 청구권자

(가) 공동상속인

상속인 중의 1인 또는 수인이 나머지 상속인 전원을 상대방으로 하여 청구하여야 한다(가사소송규칙 제110조).

공동당사자 사이에는 민사소송법 중 필수적공동소송에 관한 규정이 준용된다(가사소송법 제47조). 상속인인 이상 특별수익으로 인하여 구체적 상속분이 영(零)인 자라도 당사자 적격을 가진다. 공동상속인 중의 일부가 행방불명인 경우 행방불명자를 위한 부재자재산관리인을 선임하여 상속재산분할을 하여야 한다는 것이 다수설이다.

당사자의 일부가 미성년자인 경우 상속재산분할의 협의는 성질상 미성년자를 위한 특별대리인을 선임하여야 하고, 그 미성년자가 수인인 경우에는 미성년자 각자마다 특별대리인을 선임하여야 한다. 만약 특별대리인 1인이 수인의 미성년자를 대리하여 상속재산 분할협의를 하였다면 이는 민법 제921조에 위반된 것으로서 이러한 대리행위에 의하여 성립된 상속재산 분할협의를 피대리자의 전원에 의한 추인이 없는 한 무효이다.⁴²⁸⁾ 이는 상속재산 분할심판절차에 있어서도 마찬가지로 취급하여야 한다.

재산상속인의 존재가 분명하지 아니한 상속재산에 관한 소송에 있어서 정당한 피고는 법원에서 선임된 상속재산관리인이라 할 것이다.⁴²⁹⁾

공동상속인 사이에 어떤 재산이 상속재산임의 확인을 구하는 소가 확인의 이익이 있다.⁴³⁰⁾

426) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅱ)], 636~637면.

427) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅱ)], 608면.

428) 대법원 1994. 09. 09. 선고 94다6680 판결.

429) 대법원 1976. 12. 28. 선고 76다797 판결; 대법원 2007. 06. 28. 선고 2005다55879 판결.

430) 대법원 2007. 08. 24. 선고 2006다40980 판결: 공동상속인 사이에 어떤 재산이 피상속인의 상속재산에 속하는지 여부에 관하여 다툼이 있어 일부 공동상속인이 다른 공동상속인을 상

(나) 포괄수증자

상속인과 동일한 권리의무가 있으므로 당사자적격이 있다.

(다) 상속분의 양수인

당사자적격을 가진다. 상속분 전부를 양도한 상속인은 일반적으로 당사자적격이 없으나, 상속채무가 분할의 대상으로 되는 경우나 상속재산이 상속분양도인의 명의로 남아 있는 경우 등에 있어서는 당사자적격을 인정하여도 무방할 것이다.

(라) 태아

정지조건설과 해제조건설의 대립이 있으나, 판례⁴³¹⁾는 정지조건설을 취하고 있으므로 태아에게 상속재산분할청구의 당사자적격을 인정할 것은 아니다.

(마) 상속인의 채권자

상속인에 대한 채권자가 상속인의 상속재산분할청구권을 대위행사할 수 있는지에 관하여 적극설과 소극설의 대립이 있다.

(바) 피상속인의 사실상 배우자, 사실상의 양자

법률상 상속인에 해당하지 않으므로 당사자적격이 없다.

(사) 피상속인의 채권자, 상속재산의 일부를 매수한 자, 상속재산에 제한물권을 가지는 자

당사자적격이 없고, 이해관계인으로서 절차에 참가할 수 있을 뿐이다.

(아) 중혼배우자

상속인 적격을 갖는다.

“민법 제824조는 ‘혼인의 취소의 효력은 기왕에 소급하지 아니한다.’고 규정하고 있을 뿐 재산상속 등에 관해 소급효를 인정할 별도의 규정이 없는바, 혼인 중에 부부 일방이

대로 그 재산이 상속재산임의 확인을 구하는 소를 제기한 경우, 이는 그 재산이 현재 공동 상속인들의 상속재산분할 전 공유관계에 있음의 확인을 구하는 소송으로서, 그 승소확정 판결에 의하여 그 재산이 상속재산분할의 대상이라는 점이 확정되어 상속재산분할심판 절차 또는 분할심판이 확정된 후에 다시 그 재산이 상속재산분할의 대상이라는 점에 대하여 다툴 수 없게 되고, 그 결과 공동상속인 간의 상속재산분할의 대상인지 여부에 관한 분쟁을 종국적으로 해결할 수 있으므로 확인의 이익이 있다.

431) 대법원 1976. 09. 14. 선고 76다1365 판결.

사망하여 상대방이 배우자로서 망인의 재산을 상속받은 후에 그 혼인이 취소되었다는 사정만으로 그 전에 이루어진 상속관계가 소급하여 무효라거나 또는 그 상속재산이 법률상 원인 없이 취득한 것이라고는 볼 수 없다.”⁴³²⁾

(2) 심판청구서 작성방법

(가) 서 식

심판청구서에서는 다음의 사항을 기재하여야 한다(가사소송규칙 제114조).

- ① 이해관계인의 성명과 주소
- ② 공동상속인 중 상속재산으로부터 증여 또는 유증을 받은 자가 있는 때에는 그 내용
- ③ 상속재산의 목록

작성방법은 아래의 [서식]을 참조한다.

(나) 청구취지

청구취지는 상속재산의 분할을 구한다는 취지와 그 대상인 상속재산을 특정함으로써 족하고, 분할방법까지 구체적으로 기재할 필요는 없다.

(다) 청구취지 기재례

① 현물분할

※ 1개의 물건을 분할하는 경우

1. 별지 목록 기재 각 토지 중 제1, 2항 기재 토지는 청구인의 소유로, 같은 목록 제3, 4항 기재 토지는 상대방 김○○의 소유로, 같은 목록 제5, 6항 기재 토지는 상대방 김○○의 소유로 각 분할한다.
 2. 심판비용은 상대방들의 부담으로 한다.
- 라는 심판을 구합니다.

432) 대법원 1996. 12. 23. 선고 95다48308 판결.

※ 여러 개의 물건을 각자의 소유로 분할하는 경우

1. 별지 제1목록 기재 부동산은 청구인의 소유로, 별지 2목록 기재 부동산은 상대방 ○○○의 소유로, 별지 제3목록 기재 부동산은 상대방 △△△의 소유로 각 분할한다.
2. 가. 청구인에게, 별지 제1목록 기재 부동산 중 상대방 ○○○는 1/5지분, 상대방 △△△는 2/5의 지분에 관하여,
나. 상대방 ○○○에게, 별지 제2목록 기재 부동산 중 청구인은 1/5지분, 상대방 △△△는 2/5의 지분에 관하여,
각각 이 심판 확정일자 상속재산분할을 원인으로 한 이전등기절차를 이행하라.
3. 상대방 ○○○는 상대방 △△△에게 별지 제3목록 기재 동산을 인도하라.
4. 심판비용은 상대방들이 부담한다.
라는 심판을 구합니다.

② 경매에 의한 분할

1. 별지 목록 기재 각 부동산을 경매하여 그 대금 중 경매절차비용을 공제한 금액을 청구인에게 3/5지분, 상대방 갑분에 1/5지분, 상대방 을에게 1/5지분의 비율로 분할한다.
2. 심판비용은 상대방들의 부담으로 한다.
라는 심판을 구합니다.

③ 차액정산에 의한 현물분할의 경우

1. 별지 목록 기재 부동산을 청구인의 소유로 분할한다.
2. 상대방들은 청구인에게, 위 부동산 중 각 3/5지분에 관하여 이 심판 확정일자 상속재산분할을 원인으로 한 소유권이전등기절차를 이행하라.
3. 청구인은 상대방들에게 2011. 5. 30.까지 각 5천만 원씩 지급하라.
4. 소송비용은 상대방들이 부담한다.
라는 심판을 구합니다.

④ 재산상속회복 및 상속재산분할청구

1. 상대방 김○○은 청구인 이○○에게 돈 8,453,890원, 나머지 청구인들에게 각 돈1,408,981원 및 위 각 돈에 대하여 이 사건 심판청구서 부분 송달 다음날부터 이 심판선고일까지는 연 5분의 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 돈을 지급하라.
 2. 별지 제1목록 기재 제5 내지 제11 부동산을 경매에 붙여 그 대금에서 경매비용을 공제한 나머지 돈을 청구인 이○○에게 6/11, 나머지 청구인들에게 각 1/11의 각 비율로 분배한다.
 3. 심판비용은 상대방들의 부담으로 한다.
 4. 제1항은 가집행할 수 있다.
- 라는 심판을 구합니다.

(3) 첨부서류

가족관계증명서 1통, 기본증명서 1통, 유산목록, 부동산등기부 등본, 기여사실 소명자료, 기타서류 등이 필요하다.

(4) 청구비용

민법 제1013조 제2항에 따른 “상속재산의 분할에 관한 처분” 사건은 마류 가사비송사건 중 제10호에 해당한다. 이 심판 청구의 수수료는 해당 청구를 공유물분할청구의 소로 보아 민사소송 등 인지법 제2조를 준용하여 계산한 금액으로 한다(가사소송수수료규칙 제3조 제1항 제2호).

공유물분할의 경우 목적물가액에 원고의 공유지분비율을 곱하여 산출한 가액의 1/3을 소가로 한다(민인규 제12조7호).

송달료는 당사자의 수×5,200원×12회분이다. 법원 구내은행에 송달료예납납부서를 작성하여 납부한다.

(5) 청구서 제출(관할법원) 및 접수방법

상대방 중 1인의 주소지를 관할하는 가정법원에 제출한다. 가정법원 합의부의 사물관할에 속한다.

청구서 원본(법원용) 1통, 부분(상대방용) 1통을 준비하여 직접 상대방의 주소지를 관할하는 가정법원(가사소송법 제46조 본문)에 제출하거나, 대리인에 의하여 제출할 수 있고 대리인에 의하여 제출할 경우 위임장 1통을 준비한다. 또한 우편 접수도 가능하다.

(6) 송 달

대심적 구조의 쟁송사건인 마류 가사비송사건에 있어서는 심판청구서의 부분을 상대방에게 송달하여야 한다.

(7) 심판청구의 변경·병합·조정전치

분할이 청구된 상속재산에 관하여 기여분결정청구가 있는 때에는 이를 병합하여 심리·재판하여야 하고(가사소송규칙 제112조 제2항), 이들 병합된 사건에 대하여는 1개의 심판으로 재판한다(동조 제3항).

공동상속인 중의 1인 또는 수인이 특정한 상속재산에 대하여 분할을 청구하고, 나머지 공동상속인 중 1인 또는 수인이 다른 상속재산에 대하여 분할을 청구한 경우에는 이들 사건 역시 병합하여 처리하여야 할 것이다. 사건의 병합은 필요한 것이므로 이에 위반하여 별개로 심판하는 것은 위법이다.

조정전치주의가 적용된다.

[서식] 상속재산분할심판청구서

상속재산분할심판청구

- 청구인(상속인) 1. 장 ○ 회 (전화)
주 민 등 록 번 호
주 소 서울 ○○구 ○○대로 ○○ (우편번호)
등 록 기 준 지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)
2. 이 ○ 호 (전화)
주 민 등 록 번 호
주 소 서울 ○○구 ○○대로 ○○ (우편번호)
등 록 기 준 지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

피청구인(상속인) 이 ○ 재

주민등록번호

주 소 서울 ○○구 ○○대로 ○○ (우편번호)

등 록 기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

사건본인(피상속인) 이 ○ 화

주민등록번호

마지막 주 소 서울 ○○구 ○○대로 ○○

등 록 기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

상속재산의 표시

별지 목록 기재와 같음

청 구 취 지

1. 별지 목록 기재 부동산을 경매에 붙여 그 경매대금에서 경매절차비용을 공제한 금액을 청구인 1에게 3/7, 청구인 2에게 2/7, 상대방에게 2/7의 각 비율로 분할한다.
2. 심판비용은 상대방이 부담한다.
라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

1. 피상속인 망 이○화와 망 청구인 1은 1948. 5. 1. 혼인신고를 마치고, 슬하에 아들로 청구인 2 및 상대방(장남)을 두었습니다.
2. 피상속인은 성남시 ○○구 ○○동 536(○○로10길 12) 대지 및 지상 3층 건물을 소유하고 있었고, 20○○. 5. 25.자 예견치 못한 교통사고로 갑자기 사망하였으므로 상속인들에게 상속이 개시되었습니다.
3. 그러나 상대방은 피상속인의 생존 시에 위 부동산을 취득하는데 공헌이 컸으므로 법정비율대로 협의분할 하는 것은 타당하지 않고 단독상속을 주장하고 있음으로 청구취지와 같은 이 건 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

1. 청구인의 가족관계증명서, 주민등록등본 각 1통
1. 피상속인의 제적등본 또는 폐쇄 기본증명서, 가족관계증명서 각 1통
1. 피상속인의 말소된 주민등록등본 1통
1. 부동산등기사항전부증명서 1통
1. 확인서 1통
1. 기타(소명자료)
1. 별지목록 1통
1. 청구서부분 1통
1. 납부서 1통

20〇〇. 6. .

위 청구인 1. 장 ○ 희 (인)
2. 이 ○ 호 (인)

서울가정법원 귀중

[분할대상재산명세표]

재판부 : 제 ○ 가사부(또는 가사 ○ 단독)

사건번호 :

원고 : 피고 :

※ 주의사항

1. 아래 표에 기재하지 않은 재산은 원칙적으로 재산분할 대상으로 고려하지 아니할 예정이므로, 원고 및 피고 모두에 대하여 그 재산으로 주장하는 것은 빠짐없이 기재할 것.

2. 해당 재산에 관하여 특이사항이 있으면 비고란에 기재할 것.

3. 구체적인 명세표의 기재요령은 별지와 같음.

- 분할대상 재산의 확정 및 가액산정의 기준시점은 원칙적으로 이혼소송의 사실심 변론종결일임.
- 당사자 사이에 가액에 관한 다툼이 있을 경우 해당 자료를 반드시 제출할 것. 가액에 관한 의견이 일치하는 경우 '일치진술'로 표시할 수 있음.

4. 서울가정법원 홈페이지 '자주 묻는 질문'게시판에 아래 표의 한글파일이 게시되어 있으니, 해당 파일을 다운로드 받아 작성하여도 됨(이 경우 작성한 문서를 준비서면에 파일로 첨부하기 바람).

소유자 등		순번	재산의 표시	재산의 가액 (단위 : 원)	증거	비고
원고	적극 재산	1	서울 성북구 길음동 ○○아파트 ○동 ○호	200,000,000	을 제1호증	
		2	○○은행 예금(계좌번호 : ○○-○○-○○)	75,000,000	갑 제2호증	2014. 1. 1. 기준
		소계		275,000,000		
	소극 재산	1	서울 성북구 길음동 ○○아파트 ○동 ○호 임대 차보증금반환채무	130,000,000	갑 제10호증	
		소계		130,000,000		
	원고의 순재산			145,000,000		
피고	적극 재산	1	서울 강남구 역삼동 ○○아파트 ○동 ○호	320,000,000	갑 제7호증	
		2	경기 여주군 ○○면 ○○리 275 전 ○○㎡	15,000,000	시가감정 촉탁결과	
		3	○○생명보험 예상해지환급금 (증권번호 : ○○-○○-○○)	2,000,000	을 제4호증	2014. 1. 1. 기준
		소계		337,000,000		
	소극 재산	1	○○은행에 대한 대출금 채무(계좌번호 : ○○ -○○-○○-○)	50,000,000	금융거래정보 제출명령회신	2014. 1. 1. 기준
		소계		50,000,000		
	피고의 순재산			287,000,000		
	원·피고의 순재산의 합계			432,000,000		

[별지]

명세표 기재요령

1. 적극재산

- 가. 부동산: ‘재산의 표시’란에 소재지번 등을 기재하고, ‘재산의 가액’란에 당사자가 알고 있는 현재 기준시점의 시가를 기재한 후, 부동산등기부 등본 및 시가 입증 자료{① 아파트: 국민은행 부동산 시세 자료(<http://www.kbstar.com/>)와 국토해양부 실거래가 자료(<http://rt.molit.go.kr/>) 등 ② 기타 부동산: 가급적 감정서, 공시지가 등 객관적 자료, 이러한 자료가 없을 경우 공인중개사의 확인서 등}를 첨부하시기 바랍니다.
- 나. 예금 채권: ‘재산의 표시’란에 금융기관의 명칭, 계좌번호를 기재하고, ‘재산의 가액’란에 현재 기준시점의 예금 잔액을 기재한 후, 예금통장사본, 계좌내역, 잔액조회서 등의 자료를 첨부하시기 바랍니다.
- 다. 임대차보증금반환 채권: ‘재산의 표시’란에 부동산의 소재지번을 기재하고, ‘재산의 가액’란에 임대차보증금 금액을 기재한 후, 임대차계약서 사본을 첨부하시기 바랍니다.
- 라. 주식: ‘재산의 표시’란에 회사의 명칭, 주식의 수 등을 기재하고, ‘재산의 가액’란에 현재 기준시점의 시가를 기재한 후 주식예탁통장 사본 및 시가 입증 자료를 첨부하시기 바랍니다.
- 마. 특허권 등의 지적재산권: ‘재산의 표시’란에 다른 특허권 등과 구분이 가능한 정도로 권리를 표시하고, ‘재산의 가액’란에 당사자가 알고 있는 현재 기준시점의 시가를 기재하시기 바랍니다.
- 바. 동산: ‘재산의 표시’란에 동산의 종류 및 수량, 현재 있는 장소 등을 기재하고, ‘재산의 가액’란에 당사자가 알고 있는 현재 기준 시점의 시가를 기재하시기 바랍니다.
- 사. 자동차: ‘재산의 표시’란에 차량번호와 모델명, 출고된 연도 등을 기재하고, ‘재산의 가액’란에 당사자가 알고 있는 현재 기준시점의 시가를 기재한 후, 자동차등록증 사본, 중고차 시세를 알 수 있는 자료{해당 차량 가액이 기재된 보험계약서, 이러한 자료가 없을 경우 인터넷 중고차거래 사이트 자료, 보험개발원 차량기준가액 자료(<http://www.kidi.or.kr/>)}를 첨부하시기 바랍니다.
- 아. 보험: ‘재산의 표시’란에 보험회사, 보험의 종류 및 명칭 등을 기재하고, ‘재산의 가액’란에 현재 기준시점의 예상해약환급금(충 납부 보험료가 아님)을 기재한 후, 예상해약환급금확인서 등의 자료를 첨부하시기 바랍니다.

2. 소극재산

- 가. 사인 간 채무: ‘재산의 표시’란에 채권자 성명, 차용 일시 등을 기재하고, ‘재산의 가액’란

에 현재 기준시점의 채무액을 기재한 후 차용증 사본 등을 첨부하시기 바랍니다.

나. 금융기관 채무: '재산의 표시'란에 대출 금융기관의 명칭, 대출일 등을 기재하고, '재산의 가액'란에 현재 기준시점의 남아 있는 대출액을 기재한 후, 대출확인서, 부채증명서 등의 자료를 첨부하시기 바랍니다.

다. 임대차보증금반환 채무: '재산의 표시'란에 부동산의 소재지번을 기재하고, '재산의 가액'란에 임대차보증금 금액을 기재한 후, 임대차계약서 사본을 첨부하시기 바랍니다.

(8) 심 리

당사자가 사망한 경우에는 절차가 당연히 종료되는 것은 아니고, 그 상속인이 수계하여야 한다.

(9) 절차의 종료(심판)

(가) 심판의 범위

가정법원은 심리종결 시까지 분할이 청구된 모든 상속재산에 대하여 동시에 분할의 심판을 하여야 한다(가사소송규칙 제115조 제1항). 여기서 전부라는 것은 상속재산 전부를 의미하는 것은 아니고, 현실적으로 당사자가 분할을 청구하여 심판의 대상으로 된 재산 전부를 가리킨다.

또한 심판이 청구된 상속재산 중 일부에 대해서만 분할의 심판을 하는 것은 허용되지 않는다. 다만, 당사자의 협의나 조정에 의하여 그 일부만을 분할할 것을 주장하는 경우 금지할 이유는 없다.

(나) 심판의 주문

심판청구의 요건을 구비하지 못한 경우에는 그 심판청구를 각하할 것이고, 분할을 청구한 재산 모두가 상속재산이 아니라는 등의 경우에는 그 심판청구를 기각할 것이다. 그 밖의 경우에는 어떤 방법으로든지 간에 상속재산분할을 명하는 이상 심판청구는 인용됨 셈이어서 나머지 청구를 기각한다는 주문을 쓸 필요는 없다. 다만, 분할을 청구한 재산 중 일부가 상속재산이 아닌 것으로 판명되어 그 부분을 분할의 대상으로 삼지 아니하는 등의 경우에는 나머지 청구를 기각한다는 주문을 제기하여야 함은 성질상 당연하다.⁴³³⁾

433) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅱ)], 638면.

(다) 이행명령

상속재산분할심판에서는 금전의 지급, 물건의 인도, 등기 기타의 의무이행을 동사에 명할 수 있다(가사소송규칙 제115조 제3항, 제97조).

(라) 심판의 효력

① 상속재산분할의 소급효 : 상속재산의 분할은 상속개시 된 때에 소급하여 그 효력이 있다(민법 제1015조 본문). 그러나 분할의 소급효는 제3자의 권리를 해하지 못한다(민법 제1015조).

상세한 사항은 ‘상속재산 분할의 효과’ 371면 참조한다.

② 집행력 : 분할심판을 하면서 금전의 지급, 물건의 인도, 등기의무, 기타 물건의 급부를 동시에 명할 수 있다(가사소송규칙 제115조 제3항, 제97조). 이와 같은 심판의 주문은 집행권원이 되므로 집행력도 있다. 피상속인의 임대차보증금 반환채무는 불가분의 채무로서 상속재산 분할 대상에 포함되나, 피상속인의 차용금 채무는 상속개시와 동시에 상속인들에게 그 법정상속분에 따라 법률상 당연히 분할되어 승계되는 것으로서 상속재산 분할 대상에 포함되지 아니하고, 상속인이 상속개시 후 상속재산을 임대함으로써 발생한 임대차보증금 반환채무는 그 상속인 개인의 채무에 불과하여 상속재산 분할 대상에 포함되지 아니한다. 이 사건 상속재산의 분할방법은 피상속인의 배우자인 상속인이 상속재산인 부동산을 임대하는 등 직접 관리하고 있고 그 부동산에 대하여 기여분을 인정받았을 뿐만 아니라 다른 상속인들의 일부와 이해관계가 대립하는 등의 사정을 고려하여, 상속재산인 부동산을 배우자인 상속인에게 귀속시키고 나머지 상속인들에게 상속분에 해당하는 금원을 분할하게 함이 적당하다.⁴³⁴⁾ 심판은 형성력이 있고, 기판력은 없다.

③ 부동산에 관한 물건변동의 효력 : 상속재산인 부동산의 분할 귀속을 내용으로 하는 상속재산분할심판이 확정되면 민법 제187조에 의하여 상속재산분할심판에 따른 등기 없이도 해당 부동산에 관한 물건변동의 효력이 발생한다. 다만 민법 제1015조 단서의 내용과 입법 취지 등을 고려하면, 상속재산분할심판에 따른 등기가 이루어지기 전에 상속재산분할의 효력과 양립하지 않는 법률상 이해관계를 갖고 등기를 마쳤으나 상속재산분할심판이 있었음을 알지 못한 제3자에 대하여는 상속재산분할의 효력을 주장할 수 없다고 보아야 한다. 이 경우 제3자가 상속재산분할심판이 있었음을 알았다는 점에 관한 주장·증명책임은 상속재산분할심판의 효력을 주장하는 자에게 있다고 할 것이다.⁴³⁵⁾

434) 법원행정처, 서울가정법원 1995. 09. 07. 선고 94㉸2926 심판: 항고.

(10) 심판 후의 절차

(가) 즉시항고

상속재산분할청구를 기각한 심판에 대하여는 청구인이, 분할을 명한 심판에 대하여는 당사자 또는 이해관계인이 즉시항고를 할 수 있다(가사소송규칙 제94조 제1항, 제116조 제1항). 심판청구를 인용한 경우에도 그 분할의 방법에 관하여 불복이 있는 때에는 청구인이라도 즉시항고를 할 수 있다고 할 것이다.

(나) 선결문제에 관하여 심판과 모순, 저촉되는 판결이 확정된 경우의 심판의 효력
상속재산분할의 심판에서 공동상속인으로서의 지위가 부정된 자가 후에 사후인지, 피상속인과의 이혼무효, 파양무효, 친생자관계 존부확인 등의 판결확정으로 공동상속인의 지위를 회복한 때에는 상속재산분할심판의 효력에는 직접적인 영향을 미치지 아니하고 그 자는 민법 제1014조의 규정에 의한 상속분에 상당한 가액의 지급을 청구할 수 있다. 반대로 상속재산분할심판 후 상속인 자격을 상실시키는 내용의 확정판결이 있는 경우에는 분할심판 전체가 무효로 된다는 견해와 심판 자체의 효력에는 영향이 없고 자격을 상실한 자에게 분할된 재산을 미분할 상속재산으로 보아 다시 분할 심판을 할 수 있다는 견해가 대립되어 있으나 후설이 타당하다고 사료된다.⁴³⁶⁾

(다) 심판의 대상으로 되지 아니하였던 상속재산을 다시 심판청구를 할 수 있는지
상속재산분할의 심판은 분할이 청구된 상속재산을 대상으로 한다. 따라서 심판의 대상으로 되지 아니하였던 상속재산에 대하여는 다시 분할심판을 청구할 수 있다.⁴³⁷⁾

435) 대법원 2020. 8. 13. 선고 2019다249312 판결.

436) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅱ)], 640~641면.

437) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅱ)], 642면.

제2관 상속분할 후 피인지자 등의 청구권

(가사소송규칙 제2조 제1항 제2호, 다류 가사비송사건)

1. 의 의

상속개시후의 인지 또는 재판의 확정에 의하여 공동상속인이 된 자가 상속재산의 분할을 청구할 경우에 다른 공동상속인이 이미 분할 기타 처분을 한 때에는 그 상속분에 상당한 가액의 지급을 청구할 권리가 있다(민법 제1014조). 가령 혼인 외의 출생자 D가 아버지로부터 인지를 받지 못한 상태에서 아버지가 사망하여 다른 형제들과 같이 상속을 받지 못했다고 가정하자. D가 상속개시 후에 인지를 받거나 또는 인지청구의 소로 인지가 확정되면 다른 형제들과 같이 상속개시 당시부터 공동상속인이 된다. 따라서 아직 상속재산분할 이전이라면 당연히 다른 공동상속인과 같이 분할에 참가할 수 있다. 그러나 이미 상속재산을 분할, 기타 처분을 하였다면 다른 공동상속인에 대하여 상속분에 상당하는 가액의 지급을 청구할 수 있다. 이 경우 다시 분할을 하게 되면 제3자에게 해를 줄 염려가 있으므로 가액의 지급만 청구할 수 있도록 하였다.

2. 성 질

가. 상속회복청구권설

가액반환청구권의 본질은 혼인 외의 출생자의 상속회복청구권이라고 보아야 하며 민법 제999조 제2항의 제척기간의 제한이 있다고 하는 견해,⁴³⁸⁾ 즉 이 설이 통설이며 상속회복청구권으로 보아 상속회복청구권의 소멸에 관한 단기제척기간이 적용된다고 한다.

나. 재산분할청구권설

이 견해는 단순한 재산분할청구권이라고 한다.⁴³⁹⁾

소수설로 피인지자나 기타 재판이 확정된 자는 진정한 공동상속인으로서 상속재산의 분할 전이면 분할에 참가할 수 있고, 분할 후에 재판이 확정된 경우에는 가액지급을 청구할 수 있으며, 이는 상속재산분할청구권의 일종이라고 한다.

438) 김주수·김상용, 앞의 책, 617면.

439) 박윤직, 앞의 책(상속법), 269면; 박병호, 앞의 책, 387면.

다. 판례

판례⁴⁴⁰⁾는 “민법 제1014조에 의하여, 상속개시 후의 인지 또는 재판의 확정에 의하여 공동상속인이 된 자가 분할을 청구할 경우에 다른 공동상속인이 이미 분할 기타 처분을 한 때에는 그 상속분에 상당한 가액의 지급을 청구할 권리가 있는바, 이 가액청구권은 상속회복청구권의 일종이다.”라고 하고 있다.

인지심판확정으로 공동상속인이 된 자가 다른 공동상속인에 대하여 한 상속재산처분대금의 반환청구의 소가 상속회복청구의 소에 해당하는지? 판례⁴⁴¹⁾는 “재산상속에 관하여 진정한 상속인임을 전제로 그 상속으로 인한 소유권 또는 지분권 등 재산권의 귀속을 주장하고 참칭상속인 또는 자기들만이 재산상속을 하였다는 일부 공동상속인들을 상대로 상속재산인 부동산에 관한 등기의 말소 또는 기타 지분권의 반환 등을 구하는 경우에도 그 소유권 또는 지분권이 귀속되었다는 주장이 상속을 원인으로 하는 것인 이상 그 청구원인 여하에 불구하고 이는 민법 제999조 소정의 상속회복 청구의 소라고 해석함이 상당한바, 이 사건 청구인들은 인지심판 확정으로 피상속인의 사망 시에 소급하여 상속재산을 공동상속하였음을 원인으로 하여 그 상속분에 따른 지분권을 취득하였음을 전제로 그 지분권에 기하여 공동상속인들에 대하여 상속재산을 처분한 대금의 반환청구를 하는 것이므로 이 사건 소는 상속회복청구의 소에 해당한다.”고 하였다.

상속부동산에 관하여 진정한 상속인임을 전제로 그 상속으로 인한 소유권 또는 지분 등 재산권의 귀속을 주장하여 상속재산인 부동산에 관한 등기의 말소 등을 청구하는 경우에는 청구원인 여하에 불구하고 민법 제889조 소정의 상속회복청구의 소라고 해석하여야 하므로 민법 제982조 제2항 소정의 제척기간의 적용이 있다.⁴⁴²⁾

3. 상속분에 상당한 가액의 산정에 있어 그 기준 시기 및 방법

상속분을 모든 상속재산에 대한 것이 아니고, 적극재산에 대한 것만 의미한다.⁴⁴³⁾ 상속채무는 상속분에 따라 승계되기 때문이다. 가액의 산정기준시점은 상속재산의 분할 기타의 처분시를 기준으로 한다는 견해, 그 지급청구 시를 기준으로 한다는 견해, 사실심 변론종결시를 기준으로 한다는 견해의 대립이 있다. 민법 제1014조의 가액은 다른 공동상속인들이

440) 대법원 1993. 08. 24. 선고 93다12 판결.

441) 대법원 1982. 09. 28. 선고 80므20 판결.

442) 대법원 1978. 12. 13. 선고 78다1811 판결.

443) 박윤직, 앞의 책(상속법), 155면; 김주수·김상용, 앞의 책, 617면; 박병호, 앞의 책, 387면; 송덕수, 앞의 책, 1923면; 지원림, 앞의 책, 2053면.

상속재산을 실제 처분한 가액 또는 처분한 때의 시가가 아니라 사실심 변론종결 시의 시가를 의미한다. 즉, 가액지급청구권은 원래 피인지자가 상속개시 시에 소급하여 취득하였을 상속재산에 대한 권리(상속분)가 변환된 것으로서 그에 상당한 현물과의 등가관계를 전제로 하는 것이므로, 그 가액은 실제로 다른 공동상속인들이 분할 기타 처분에 의하여 얻은 대가를 기준으로 하거나 그 당시의 시가로 산정할 것이 아니라 현실의 지급시를 기준으로 하여 산정하여야 하고, 소송으로써 지급을 청구하는 경우에는 그 소송의 사실심 변론종결 당시의 상속재산가액을 기초로 하여 산정하여야 하며, 이 경우 다른 공동상속인들이 상속재산을 처분하는 방법에 의하여 이를 분할하였다거나 현실의 지급시 또는 사실심 변론종결 당시의 가액이 분할 당시의 그것보다 현저하게 등귀하였다는 사정에 의하여 결론을 달리할 수는 없으며, 따라서 그 가액의 범위에 관하여는 부당이득반환의 범위에 관한 민법규정을 유추적용할 수 없고, 다른 공동상속인들이 분할 후에 상속재산을 그대로 보유하고 있는지 여부, 처분한 금액이나 그 당시의 시가가 얼마인지 여부, 그 이익이 현존하는지 여부, 상속재산의 과실을 계속 취득하고 있었는지 아니면 상속재산을 처분하여 더 이상 그 과실을 취득하지 않고 있는지 여부, 장래에도 상속재산의 과실을 계속 취득하게 되는지 여부, 다른 공동상속인들이 분할 기타 처분 시에 피인지자의 존재를 알았는지의 여부 등과는 무관하게 현실의 지급 시(사실심 변론종결 당시)를 기준으로 상속재산이 분할되지 아니한 상태를 가정하여 평가한 가액 중 분할 후 피인지자의 상속분에 해당하는 가액을 산정하게 된다.⁴⁴⁴⁾

4. 기여분과의 관계

상세한 사항은 ‘기여분의 결정’ 196면 참조한다.

5. 상속분상당 가액지급청구

가. 당사자

청구권자는 상속개시 후의 인지 또는 재판의 확정에 의하여 공동상속인이 된 자이다. 즉, 피상속인의 사후에 인지청구의 소를 제기하여 인지의 판결을 얻은 자, 피상속인의 생전에 인지청구의 소를 제기하였으나 그 피상속인의 사후에 인지의 판결을 얻은 자, 피상속인과의 친생자자녀관계존재확인의 소를 제기하여 그 확인의 판결을 얻은 자, 부를 정하는

444) 대법원 1993. 08. 24. 선고 93다12 판결; 대법원 2002. 11. 26. 선고 2002므1398 판결.

소를 제기하여 피상속인이 부임을 확인하는 판결을 얻은 자, 피상속인을 피고로 하여 이혼 무효의 소를 제기하여 그 승소로 피상속인과의 혼인이 계속되는 것으로 확정된 자, 피상속인을 피고로 하여 파양무효의 소를 제기하여 그 승소로 피상속인과의 양자녀관계가 계속되는 것으로 확정된 자 등이다. 상대방은 다른 공동상속인이다. 다른 공동상속인은 상속인의 지위에 있게 된 피인지자등과 공동상속인의 지위에 있게 되는 자를 말한다.

나. 첨부서류

확정판결등본, 가족관계증명서, 기타 첨부서류 등을 준비한다.

다. 소송비용

가류 및 나류 가사소송사건의 소의 제기의 수수료는 1건당 20,000원으로 한다(가사소송 수수료규칙 제2조제1항). 가류 가사소송사건의 송달료는 당사자의 수×5,200원(1회분)×15회분이다. 법원 구내은행에 송달료예납납부서를 작성하여 납부한다.

라. 소장제출(관할법원)

상대방인 피고의 주소지를 관할하는 가정법원에 제출한다. 사물관할은 청구가액이 5천만 원을 초과하는 경우에는 가정법원의 합의부의 사물관할에 속하고, 그 밖의 경우에는 가정법원 단독판사의 사물관할에 속한다. 피인자 등의 상속분에 상당한 가액의 지급청구는 상속회복청구의 일종이고, 상속회복청구권에는 제척기간의 정함(민법 제999조 제2항)이 있으므로 피인자 등의 상속분에 상당한 가액의 지급청구 역시 상속의 침해를 안 날로부터 3년, 상속권의 침해행위가 있는 날부터 10년 내에 청구하여야 한다.⁴⁴⁵⁾ ‘상속권의 침해를 안 날’이라 함은 자기가 진정상속인임을 알고 또 자기가 상속에서 제외된 사실을 안 때를 가리킨다. 따라서 혼인 외의 출생자가 법원의 인지판결 확정으로 공동상속인이 된 때에는 그 인지판결이 확정된 날에 상속권이 침해되었음을 알았다고 할 것이다.⁴⁴⁶⁾

소장 원본(법원용) 1통, 부분(상대방용) 1통을 준비하여 직접 관할 가정법원에 제출하거나, 대리인에 의하여 제출할 수 있고 대리인에 의하여 제출할 경우 위임장 1통을 준비한다. 또한 우편 접수도 가능하다.

445) 대법원 1981. 02. 10. 선고 79다2052 판결.

446) 대법원 2007. 07. 26. 선고 2006므2757, 2764 판결.

마. 소장접수 후 법원의 조치, 소장심사, 소장부분의 송달

소장을 관할법원 가사신청과 접수담당자에게 제출하면 접수담당자는 소송서류 기타 사건관계 서류의 접수를 거부할 수 없다. 법원은 원고로부터 수리한 소장을 피고에게 소장 부분 및 소송절차안내서를 송달한다.

바. 소장 작성방법

[서식] 상속분상당가액지급청구의 소

소 장

- 원 고 안 ○ 민 (주민등록번호 :)
 주 소 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)
 등록기준지 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동)
 전화번호 : 팩 스 :
- 피 고 1. 장 ○ 혼 (주민등록번호 :)
 주 소 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)
 등록기준지 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동)
2. 박 ○ 성 (주민등록번호 :)
 주 소 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)
 등록기준지 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동)
3. 박 ○ 훈 (주민등록번호 :)
 주 소 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)
 등록기준지 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동)

상속분상당가액지급청구의 소

청 구 취 지

1. 원고에게, 피고 1은 금 1,140,961,855원, 피고 2는 금 10,591,453,987원, 피고 3은 금 10,559,936,504원 및 위 각 금원에 대하여 199○. 10. 8.부터 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일까지 연 5%, 그 다음날부터 완제일

까지 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급 받기 위해 이 건 청구에 이른 것입니다.

2. 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.

3. 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 기초적 사실관계

가. 피상속인 망 소외 1은 소외 2와 사이에 혼인신고를 하지 아니한 채 1950. 6. 10. 원고1를 낳았고, 소외 2는 1960. 9. 3. 망 소외 1의 동의 없이 임의로 망 소외 1과의 혼인신고를 하였고, 같은 날 원고 및 피고1를 자신과 망 소외 1사이의 친생자로 출생신고를 하였으며, 이에 소외 2와 원고 등은 소외 1의 가족관계등록부에 그의 처 및 자로 각 등재되었습니다.

나. 그 후 망 소외 1의 모 망 소외 3은 서울가정법원에 소외 2와 망 소외 1을 상대로 혼인무효확인심판청구를 하였고, 그 무렵 위 법원은 소외 2와 망 소외 1사이의 위 혼인이 무효임을 확인한다는 내용의 심판을 선고하였으며, 소외 2가 이에 불복하여 항소하였으나 항소심인 서울고등법원은 1960. 7. 15. 그 항소를 기각하였고, 다시 소외 2가 이에 불복하여 상고하였다가 그 상고를 취하여 혼인무효확인심판은 확정되었고, 원고는 혼인 외의 자로 되었습니다.

다. 망 소외 1은 혼인무효확인심판이 확정된 후인 1960. 6. 1. 피고 1과 혼인신고를 마친 후 그 사이에서 1960. 3. 18. 피고 2를, 1970. 6. 26. 피고 3을 낳았고, 한편, 망 소외 1은 위 혼인무효확인심판 확정 후에도 원고 등이 여전히 자신의 가족관계등록부에 등재되어 있자 1960년 서울가정법원 60드877호로 원고 등을 상대로 인지무효심판청구를 하였고, 서울가정법원은 1960. 9. 6. 망 소외 1이 1960. 9. 3.자로 원고 등을 자로 한 인지(출생신고)가 무효임을 확인한다는 내용의 심판을 선고하였으며, 그 심판은 1960. 9. 21. 확정되었고, 이에 따라 원고 등은 그 무렵 망 소외 1의 가족관계등록부에서 말소되었습니다.

라. 망 소외 1은 1994. 11. 30. 사망하였고, 원고 등은 1990. 1. 4. 서울가정법원 90드461호로 검사를 상대로 인지의 소를 제기하였으며, 서울가정법원은 1990. 12. 5. 원고 등을 망 소외 1의 친생자로 인지한다는 내용의 판결을 선고하였고, 보조참가인이었던 피고들이 이에 불복하여 서울고등법원 90르89호로 항

소하였으나 서울고등법원은 199○. 11. 6. 그 항소를 기각하였으며, 다시 피고들이 이에 불복하여 대법원 9○트1698호로 상고하였으나 대법원이 199○. 10. 8. 그 상고를 기각하여 위 판결은 같은 날 확정되었습니다.

2. 상속분상당가액반환청구권의 발생 및 법정상속분

가. 위 사실에 의하면, 원고 등은 위 인지판결의 확정에 따라 출생 당시에 소급하여 망 소외 1과 사이에 법률상 친생자관계가 성립하였다 할 것이고, 따라서 망 소외 1의 사망 당시 이미 피고들과 함께 공동상속인이었으나, 위 인지판결이 확정되기 전 이미 피고들이 망 소외 1의 상속재산 중 일부를 협의분할하였는바, 인지의 소급효로써 제3자가 취득한 권리를 해할 수는 없으므로 원고로서는 피고들을 상대로 이미 분할된 상속재산 그 자체의 재분할을 구할 수는 없고, 민법 제1014조에 의하여 피고들을 상대로 이미 분할된 상속재산 중 자신의 상속분에 상응하는 가액을 청구할 수 있게 된다 할 수 있습니다.

나. 한편, 위 인정 사실에 의하면 처 피고 1은 3/11지분, 자녀들인 원고 및 피고 2, 3, 상대방은 각 2/11지분의 비율로 법정상속분을 가진다고 할 수 있습니다.

3. 피고들이 분할 받은 상속재산가액

가. 피고 1이 분할받은 상속재산의 상속개시일 기준 가액은 금 2,374,818,478원, 피고 2가 분할 받은 상속재산의 상속개시일 기준 가액은 금 41,451,522,434원, 피고 3이 분할받은 상속재산의 상속개시일 기준 가액은 금 47,365,294,240원으로,

나. 피고들이 분할 받은 상속재산의 가액 합계액에서 상속세를 공제한 가액은 상속개시일 기준으로 금 67,948,733,916원{= 상속재산의 상속개시일 기준 가액 91,191,635,152원(= 2,374,818,478원 + 41,451,522,434원 + 47,365,294,240원) - 상속세의 상속개시일 기준 환산액 23,242,901,236원}입니다.

4. 결 론

그렇다면, 원고에게, 피고1은 금 1,140,961,855원, 피고2는 금 10,591,453,987원, 피고 3은 금 10,559,936,504원 및 위 각 금원에 대하여 199○. 10. 8.부터 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일까지 연 5%, 그 다음날부터 완제일까지 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급 받기 위해 이 건 청구에 이른 것입니다.

입 증 방 법	
1. 갑 제1호증의 1 내지 2	가족관계증명서(원고, 피고)
1. 갑 제2호증의 1 내지 2	주민등록등(초)본
1. 갑 제3호증	제적등본
1. 갑 제4호증의 1 내지 10	부동산등기사항전부증명서
1. 갑 제5호증의 1 내지 10	감정서
첨 부 서 류	
1. 위 입증방법	각 1통
1. 소장부분	1통
1. 납부서	1통
20〇〇. 4. .	
원 고 안 ○ 민 (인)	
서울가정법원 귀중	

사. 심리절차·판결의 효력

다류 가사소송사건은 본질이 민사사건이므로 그 소송절차는 원칙적으로 민사소송법의 규정에 의한다(가사소송법 제12조 본문). 따라서 일반 민사사건과 같이 변론주의의 지배를 받아 주요사실은 당사자가 변론에서 주장하여야 하고 당사자에 의하여 주장되지 않는 사실은 판결의 기초로 삼을 수 없다. 또한 자백에는 구속력이 있어 법원이 그에 반하는 사실인정을 할 수 없고, 당사자가 신청한 증거에 한하여 증거조사를 하여야 한다. 그러나 다류 가사소송사건도 가사사건의 일종이므로 일정한 범위 내에서는 일반 민사사건과 다른 취급을 받는다. 즉, 가정법원의 관할에 전속하고(동법 제2조), 가사조사관에 의한 사실조사를 행할 수 있으며(동법 제6조), 변론기일에는 본인출석주의가 적용되고(동법 제7조), 항소심절차에서는 사정판결을 할 수 있다(동법 제19조 제3항).

기관력의 주관적 범위에 관하여 가사소송법 제21조는 “가류 또는 나류 가사소송사건의 청구를 인용한 확정판결은 제3자에게도 효력이 있다.”라고 규정하고 있으나, 다류 가사소

송사건에는 적용되지 아니한다. 따라서 확정판결의 기판력은 당사자 사이에서만 발생하고 제3자에게는 효력이 없다.

가사소송법 제12조는 “가사소송절차에 관하여는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 민사소송법 규정에 따른다.”고 하면서, 가·나류 가사소송사건은 민사소송법 제220조 중 청구의 인낙(피고가 소송물인 법률관계의 존부에 관한 원고의 주장을 무조건 승인하는 법원에 대한 진술)에 관한 규정의 적용은 배제하고 있다.

아. 판결 후의 조치(상소, 재심)

판결에 대해 불복을 하려면 판결문正本이 송달된 날로부터 14일내에 항소를 하면 된다. 항소기간 내에 항소하지 않거나 미리 항소포기서 등을 제출한 경우에는 판결이 확정된다.

자. 후순위상속인이 분할한 경우

(1) 문 제

인지 또는 재판의 확정에 의하여 공동상속인보다 선순위권리자로 되었으나 이미 상속재산을 후순위상속인들이 분할한 경우 어떻게 처리할 것인가 문제이다. 예컨대 피상속인에게 직계비속이 없는 것으로 알고 피상속인의 배우자와 직계존속이 상속을 하거나, 또 직계존속·배우자도 없어서 피상속인의 형제자매가 상속을 하고, 상속재산을 분할하였는데, 재판의 확정에 의하여 피상속인의 직계비속이 나타난 경우이다.

(2) 학 설

직계존속은 표현상속인에 불과하므로 상속회복청구가 가능하다고 보아야 하지만 거래의 안전을 위하여 제1014조를 유추하여 가액의 지급을 청구할 권리를 가지는 데 지나지 않는다고 한다.⁴⁴⁷⁾

(3) 판 례

혼인 외의 출생자가 부의 사망 후 인지의 소에 의하여 친생자로 인지 받은 경우 피인지자보다 후순위 상속인인 피상속인의 직계존속이나 형제자매는 피인지자의 출현으로 자신이 취득한 상속권을 소급하여 잃게 되는지 여부에 대하여, 판례는 민법 제860조는 인지의 소급효는 제3자가 이미 취득한 권리에 의하여 제한받는다는 취지를 규정하면서 민법 제

447) 박윤직, 앞의 책(상속법), 156면; 김주수·김상용, 앞의 책, 618면; 박병호, 앞의 책, 387면; 이경희, 앞의 책, 453면.

1014조는 상속개시 후의 인지 또는 재판의 확정에 의하여 공동상속인이 된 자는 그 상속분에 상응한 가액의 지급을 청구할 권리가 있다고 규정하여 제860조 소정의 제3자의 범위를 제한하고 있는 취지에 비추어 볼 때, 혼인 외의 출생자가 부의 사망 후에 인지의 소에 의하여 친생자로 인지 받은 경우 피인지자보다 후순위 상속인인 피상속인의 직계존속 또는 형제자매 등은 피인지자의 출현과 함께 자신이 취득한 상속권을 소급하여 잃게 되는 것으로 보아야 하고, 그것이 민법 제860조 단서의 규정에 따라 인지의 소급효 제한에 의하여 보호받게 되는 제3자의 기득권에 포함된다고는 볼 수 없다고 한다.⁴⁴⁸⁾ 따라서 피인지자는 그에게 상속회복청구권을 행사할 수 있다.

(4) 검토

피인자 등보다 후순위인 상속인의 상속권은 민법 제860조 단서에 의하여 보호 받는 제3자의 기득권에 포함되지 않으므로, 후순위상속인은 민법 제1014조의 공동상속인에 포함되지 않는다는 판례의 입장이 타당하다.⁴⁴⁹⁾

(5) 기타 문제

(가) 피인지자의 상속분상당가액지급청구 시 이미 분할을 완료한 다른 공동상속인들 간의 지급액 안분 비율

피인지자의 상속분상당가액지급청구 시 이미 다른 공동상속인들이 분할을 완료한 경우 피인지자 등은 그 분할로 인하여 다른 공동상속인들이 현실적으로 취득한 이익의 비율, 즉 협의 또는 심판에서 정한 분할비율에 따라 안분한 금액을 다른 공동상속인들에게 청구하는 것이 원칙이나, 상속분상당가액산정의 기초가 되는 상속재산의 범위 및 그 가액 등이 다투어지는 경우 피인지자 등이 그 결과를 예측하여 구체적으로 분할비율을 정하여 청구할 것을 기대하기는 현실적으로 어려우므로 피인지자 등으로서는 다른 공동상속인들에게 그 법정상속분에 따라 안분한 금액을 청구할 수도 있다.⁴⁵⁰⁾

(나) 상속재산의 분할 후 인지 또는 재판의 확정에 의하여 공동상속인이 된 자가 다른 공동상속인에게 이미 분할된 상속재산으로부터 발생한 과실을 부당이득으로 반환청구할 수 있는지 여부

448) 대법원 1993. 03. 12. 선고 92다48512 판결; 대법원 1974. 02. 26. 선고 72다1739 판결.

449) 송덕수, 앞의 책, 1923면; 지원림, 앞의 책, 2053면.

450) 서울가정법원 2004. 09. 16. 선고 2000느합61, 2002느합133 판결.